

법학적 관행 이론 소묘(素描)* **

—관행의 규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로—

이현경***

DOI: 10.22286/kjlp.2017.20.3.001

* 본고는 신진법철학자의 학위논문을 소개하는 취지로 기획된 학술대회 발표를 위해 작성되었다. 특히 본고는 필자가 〈2017년 한국법철학회 춘계학술대회〉(2017.6.17.)에서 발표한 원고 “법학적 관행 이론 소묘: 관행의 규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로”와 〈2017 IVR World Congress (XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy(IVR) in Lisbon, Portugal)〉(2017.7.17.-7.21.)에서의 원고 “Three dimensions of Discourse on Normativity of Convention: Conceptual analysis, Justification, and Evaluation”을 수정·보완한 것이다. 그 내용은 필자의 법학박사학위논문 “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로”(서울대학교, 2016.8.)에 상당히 의존하고 있다. 따라서 본고의 본문과 각주 일부가 필자가 이전에 다른 학술지에 게재한 논문들과 불가피하게 내용상 중복되는 점이 있다. (각 논문은 해당 부분에서 명기하였다.) 구성적 측면에서 보면, 이 논문이 체계화된 ‘법학적 관행 이론’ 정립이라는 필자의 연구 프로젝트의 축약·완성본이라고 할 수 있다. 본고는 일반 논문과 동일하게 심사위원회의 심사를 거친 후, 연구윤리 상 중복게재 등의 오해를 피하기 위해 필자의 요청에 따라 편집위원회와의 협의를 거쳐 ‘비정규논문’으로 처리하기로 함을 밝혀둔다.

** 필자가 제목에 붙인 ‘소묘(素描)’라는 표현은 두 가지 의미를 갖는다. 첫째, 본고는 법학적 관행 이론 구상을 위한 일깨워 주는 일종의 설계도 역할을 한다. 둘째, 흄(David Hume)이 말한 해부학자와 화가의 구분에 기초하여 말하면, 이 연구는 해부학적인 분석적 탐구를 기반으로 하지만 궁극적으로는 구상화를 그리는 화가로서의 작업을 지향한다고 볼 수 있다.

*** 서울대 법이론연구센터 전임연구원, 대구경북과학기술원 대우교수, 법학박사.

**** 투고일자 2017년 11월 10일, 심사일자 2017년 12월 6일, 게재확정일자 2017년 12월 8일.

〈국문초록〉

본고는 관행(convention)을 본격적인 법적 문제로 다루고, 이를 위한 분석틀을 제시하는 체계적인 ‘법학적 관행 이론’ 정립을 목표로 한다. 오늘날 관행은 사회·문화적 영역을 넘어 법적 장(場)의 한가운데 들어와 있다. 관행과 관련된 사회 문제가 사법적 분쟁으로 비화되기도 하고, 이를 입법적으로 해결하기 위해 법제화가 추진된다. 그럼에도 불구하고 정작 관행 그 자체에 대한 체계적인 법이론적 탐구는 거의 찾아보기 어렵다. 이러한 문제의식 하에, 필자는 법학적 관행 이론을 규범성 담론의 세 차원—개념분석·정당화·평가—을 중심으로 세 단계로 구성하고자 한다. 첫 번째 단계인 ‘개념분석적 차원’에서는 우선 ‘관행성’의 본질을 규명한 후, 기존의 사회적 관행 이론들의 한계를 보완하고 ‘법적’ 특수성을 반영한 대안적인 ‘법적 관행’ 개념을 정립한다(‘법적 관행 정식’). 두 번째 단계인 ‘정당화 차원’에서는 관행이 갖는 규범성의 특징을 밝히고, 규범성의 원천 및 효력 근거를 고찰한다(‘관행의 규범적 위계’ 및 ‘다층적 정당화 논변’). 마지막 세 번째 단계인 ‘평가적 차원’에서는 소위 ‘나쁜 관행’의 문제를 소재로 삼아, 그것의 논리적 가능성과 의미, 심사 기준 및 해결 방안을 논한다(‘관행존중의 원칙’ 및 ‘추정적 효력테제’). 이러한 탐구를 통해 필자가 법학적 관행 이론의 각 단계별로 도출하는 결론을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 관행 정식을 충족한 진성 관행은 특별한 종류의 규범이다[1단계: 개념분석적 차원(Ⅱ)]. 둘째, 관행은 규범적 위계를 가지며, 관행 규범성의 원천(源泉)은 다층적 논변으로 정당화될 수 있다[2단계: 정당화 차원(Ⅲ)]. 셋째, 진성 관행은 추정적 효력이 있지만, ‘나쁜 관행’의 경우에는 그 효력이 부인되며 일반적인 준수 의무가 없다[3단계: 평가적 차원(Ⅳ)]. 본고의 법학적 관행 이론은 일차적으로는 실정법학이나 법실무에 적용 가능한 실천 이론이기를 지향하지만, 동시에 대안적인 ‘법철학적 법관행주의’ 구상을 위한 토대로서도 중요한 의미를 갖는다.

I. 법학적 관행 이론¹⁾의 필요성과 가능성

1. 문제의 제기

2009년 1월, 용산참사로 대한민국이 아팠다. 그 비극의 배후에는 ‘상가권리금 수수 관행’을 둘러싼 법적 분쟁이 있었다.²⁾ 그리고 2015년 5월, ‘상가건물 임대차보호법’이 개정되었다. 의료계의 오랜 관행이 소위 ‘보라매병원 사건’³⁾과 연대세브란스 ‘김할머니 사건’⁴⁾의 판례를 계기로 2016년 2월, ‘호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률’로 법제화되었다. 2014년 4월, 세월호참사로 온 국민이 울었다. “불법은 아니지만 잘못된 관행” “비정상 관행의 정상화”라는 정부 슬로건은 국민적 공분을 집약한다. 2016년 5월, ‘부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률’이 제정되었다.

대한민국을 떠들썩하게 했던 이러한 사건들의 배후에는 각 영역에서 ‘관행(convention)’이란 이름으로 만연해온 ‘그 무엇’의 실체를 둘러싸고 관행의 존부와 효력에 대한 뿌리 깊은 논쟁이 자리한다. 그런데 정작 ‘관행’이 무엇지를 물으면 누구도 쉽사리 답을 주지 못한다. 그렇다면 관행 개념은 굳이 언어로 표현하고 명제화할 필요가 없을 만큼 이론(異論)의 여지없이 자명한 그 무엇

1) 본고에서는 ‘법학적 관행 이론’과 ‘법이론으로서 관행 이론’이라는 표현이 혼용된다. 전자는 ‘실정법학적 문제’와 후자는 ‘법철학적 문제’와 깊은 관련을 함축하는 인상을 줄 수 있다. 공통된 번역어로 ‘jurisprudential’을 생각하나, 특히 평가적 차원의 경우에는 입법이론적(‘legisprudence’) 고찰도 포괄하기에 적절한 역어를 정하기가 쉽지 않다. 이러한 두 가지 점(‘실정법학적’과 ‘입법이론적’)을 포괄하는 포용적 용어의 필요성을 고려한 일종의 차선책으로 ‘legal’이라는 용어를 광의의 ‘법적’이란 의미로 사용한다.

2) 권리금을 회수하지 못한 임차인과 임대인의 대립이 ‘용산참사’와 같은 사회문제로 이어졌다는 분석과 평이 있다. 김정옥, “권리금에 대한 법경제학적 접근,” 한국개발연구원, 2010, 4면 이하; 신옥영, “상가건물임대차보호법의 권리금 회수기회 보호에 관한 연구,” 서울대학교대학원 법학박사학위논문, 2017, 105면 재인용.

3) 대법원 2004.6.24.선고 2002도995 판결.

4) 대법원 2009.5.21.선고 2009다17417 전원합의체 판결.

인가? 하지만 우리가 접하는 수많은 분쟁들은 결국 관행에 대한 다양한 인식 불일치를 방증한다. 관행이 도대체 무엇이길래 너도나도 ‘관행’을 말하면서 마치 전가의 보도처럼 휘두르는 것일까? 한쪽에서는 관행을 상식의 산물이자 민주적인 자율적 질서라고 주장한다. 그리고 기존에 존재해온 관행을 인정해주고 그 실현을 보호해달라고 외치거나 심지어 면피를 위한 수단으로 활용하기도 한다.⁵⁾ 또 다른 한쪽에서는 관행을 혁파나 근절의 대상으로 말한다. 관행에 대한 일부 극단적인 부정적 인식은 관행을 적폐(積弊)와 등치시키곤 한다. 어떤 대상에 대한 적절한 이해의 부족은 불필요한 오해를 낳고, 부정적인 실천적 효과를 야기한다. 따라서 관행을 둘러싼 이러한 혼란을 불식하고 그로 인한 부작용을 막기 위해서는, 그저 직관에 호소하거나 일상적 담론에 의존하는 것을 넘어 관행의 개념과 규범성에 대한 적확하고 체계적인 탐구가 요청된다. 말하자면, ‘관행’이라는 블랙박스(black box)를 열어보자. 어떻게? 체계적인 이론이 필요하다. ‘법학적 관행 이론’(이하 ‘대안 이론’으로 약칭함). 본고는 바로 이 문제를 직접적으로 다루고자 한다.

2. 법학적 관행 이론의 세 단계: 규범성 담론의 세 차원⁶⁾

전술한 바와 같이, ‘관행’의 문제는 우리의 일상생활이나 사회·문화 영역을 넘어 이제 본격적인 ‘법적’(입법·사법적) 문제의 장 한가운데 들어와 있다. 하지만 법이론⁷⁾과 법적 실천(legal practice)⁸⁾의 맥락에서 관행 그 자체에 대한

5) 예컨대 소위 ‘미술계의 관행’과 조영남 사건 등.

6) 권리 담론과 관련하여 논의의 세 차원을 구분한 시도로는, 김도균, “권리담론의 세 차원: 개념분석, 정당화, 제도화,” 『법철학연구』 제7권 제1호, 한국법철학회, 2004; 『서울대학교 법학』 제48권 제2호, 2007; 김도균, 『권리의 문법—도덕적 권리·인권·법적 권리』, 박영사, 2008; 반면에 김현철 교수는 ‘정당화의 메커니즘’과 ‘실현의 메커니즘’을 구분하면서, 두 측면에서 권리의 개념 구조를 파악할 필요성이 있다고 주장한다. 김현철, “형식적 권리론—권리의 개념구조에 대하여,” 『법철학연구』 제5권 제1호, 2002, 129-130면.

7) ‘법에 있어서의 관행’은 법이론적 관점에서 보면 다양한 차원에서 중요한 의미를 갖는다. 간단히 표로 정리하면 다음과 같다.

법과 관행의 관계에 대한 이러한 법이론적 입장들은 독립적이거나 상호 배타적인 관계에 있지 않다. 위의 분류에 따른다면, 본고에서의 논의는 “법원으로서의 관

체계적인 이론적 탐구는 거의 찾아보기 어렵다. 이러한 배경 하에 본고에서 필자는 관행의 문제를 본격적인 법학적 문제로 다루고자 한다.⁹⁾

체계적인 법학적 관행 이론 정립이라는 목표를 구체화하기 위한 방법론으로 필자는 특히 관행의 규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로 접근한다. ‘규범성(normativity)’의 문제는 각종의 이론 및 실천 철학 영역에서 중요하게 다뤄지는 주제 중 하나이다. 그런데 특히 법철학 혹은 법이론의 영역에서라면, 규범성 담론은 세 차원—개념분석·정당화·평가—에서 다뤄질 필요가 있다. 본고에서 필자는 각 차원에서 단계별로 다음의 점들을 밝히고자 한다.

첫째, 관행 정식을 충족한 진성 관행¹⁰⁾은 특별한 종류의 규범이다. [1단계: 개념

[표 1] 법에 있어서의 관행: 세 차원과 상호관계

T1	“관행으로서의 법”		〈포괄적 법본성론〉
T2	“법원(法源)으로서의 관행”		
T3	“법의 토대에 있어서의 관행”		〈토대 관행주의〉
	T3-㉔	“LAW”: 궁극적 토대 관행	하트(Hart) 버전
	T3-㉕	“laws”: 비궁극적 관행	풀러(Fuller) 버전
※ T1 ⊇ T2 ∪ T3			

행”(T2)과 “비궁극적 토대 관행”(T3-㉕)으로 이어지는 노선에 상대적으로 더 가깝다고 볼 수 있다. 보다 자세한 설명은 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 서울대학교 법학박사학위논문, 2016, 제5장 제3절 참고.

8) 흔히 ‘법실무’로 표현되는 ‘legal practice’는 그 번역어의 어감으로 인하여 법전문가들의 법적 실천, 특히 재판실무로 축소되어 이해되는 경향이 있다. 하지만 본고에서 필자가 염두에 둔 것은 일반 시민들의 법생활을 포함한 가장 넓은 의미에서의 ‘법적 실천’이다. 따라서 기존 학계에서의 관용어인 ‘법실무’ 대신 ‘법적 실천’이라는 표현을 사용한다.

9) 이와 유사한 시도로는 최송화, “공익의 법문제화,” 『서울대학교 법학』 제47권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2006; 최송화, 『공익론』, 서울대학교 출판문화원, 2013.

10) ‘진성 관행(genuine convention)’이란 표현은 David Lewis의 저서 *Convention* (1969)에서 차용한 것이다. ‘진성’이란 표현이 종종 ‘도덕적인’으로 오해되기도 하지만, 이는 도덕적 함축과는 무관하다. 후술하듯, 이는 ‘임의성’과 ‘일반적 준수의존성’이라는 관행성(conventionality)의 두 필수 요건을 충족한 관행을 의미한다. 이와 대조되는 것으로는 ‘비진성 관행’ 혹은 ‘사이비 관행(pseudo-convention)’을 들

분석적 차원¹¹⁾ (II장)

둘째, 관행은 규범적 위계를 가지며, 관행 규범성의 원천(源泉)은 다층적 논변으로 정당화될 수 있다. [2단계: 정당화 차원 (III장)]

셋째, 진성 관행은 추정적 효력이 있지만('추정적 효력 테제'), '나쁜 관행'의 경우에는 그 효력이 부인되며 준수 의무가 없다. [3단계: 평가적 차원 (IV장)]¹²⁾

위의 논제들은 궁극적으로 필자가 제안하는 '법학적 관행 이론'의 각 단계를 구성하며, 동시에 규범성 담론의 세 차원에서의 결론으로 볼 수 있다. 이러한 체계를 기초로 본고는 다음과 같이 구성된다. 법학적 관행 이론의 1단계이자 '개념분석적 차원'에서는 '법적 관행'의 개념과 본질을 규명한다. 이를 위해 우선 현대의 대표적 관행 이론가인 루이스(David Lewis)의 관행 정식을 비판적으로 검토한 후(II-1.), 대안적인 '법적 관행 정식'을 제안하고 그 요건을 검토한다(II-2.). 그리고 관행의 존재론적 지위를 개념과 실례(instance)의 두 차원으로 구분하여 논한 후, "관행≒규범(=규범적 규칙) * 사회적 실천(social practice)"으로 재규정한다(II-3.). 다음으로 법학적 관행 이론의 2단계이자 '정당화 차원'에서 "규범으로서 관행"을 다각도로 고찰한다. 필자는 규범적 관행의 특수성을 '규범적 위계'와 '규범력의 정도', 그리고 '제도적 위계'의 면에서

수 있다. 이런 유형은 흔히 '관행'이라 불리긴 하지만 본고의 이론에 따르면 진정한 의미에서 '관행'이라고 할 수 없다. 루이스 역시 유사한 입장을 보인다. "어떤 조정 균형이 두 요건을 충족하지 못한다면 그것은 조정 균형이긴 하지만 '관행' 아닌 것(nonconvention)"이다." David Lewis, *Convention*, Blackwell Publishing, 1969, pp.45-46. 우리는 '진성 관행'에 대해서만 그 효력 및 복종의무 등을 논하고 다룰 수 있다는 것이 필자의 생각이다.

- 11) 필자는 본고에서 '법학적 관행 이론의 세 단계'를 곧 '규범성 담론의 세 차원'과 호환하고 있다. 그 중 첫 번째 단계인 '개념분석적 차원'이 왜 규범성 담론에 속하는지를 의아해할 수 있다. 그 이유는 필자의 법적 관행 정식에 따르면 진성 관행은 개념내재적으로 규범성과 결부되기 때문이다.

- 12) 이를 포괄적인 연구 목표의 방식으로 재규정하면 다음과 같다.

- ① 관행의 개념과 존재 조건, 규범성의 원천 및 정당화 근거
- ②-A. 관행성을 보존하면서도, 변화와 혁신의 가능성을 허용하는 유연한 관행 개념과 동적 이론: 개념과 본성의 문제: <일반이론 차원>
- ②-B. 관행성의 극단화를 제어하고, '나쁜 관행'을 평가할 수 있는 이론: 효력과 평가의 문제: <법이론 차원>

밝힌다(III-1). 또한 관행의 내적 규범성에 대한 가장 강력한 옹호자인 길버트(Margaret Gilbert)의 관행 이론을 비판적으로 검토한 후 한계를 지적하고 특히 법의 영역에 적합한 대안 이론의 필요성을 확인한다(III-2). 관행이 갖는 규범성의 원천을 정당화하기 위한 여러 후보 논변들을 제시한 후, 최종적으로 ‘다층적 정당화 논변’을 주장한다(III-3). 법학적 관행 이론의 3단계이자 ‘평가적 차원’에서는 일종의 병리현상인 소위 ‘나쁜 관행’의 문제를 소재로 삼아 관행의 규범성을 재고한다. 진성 관행이 갖는 ‘추정적 효력’을 해명하고(IV-1), 임계점을 넘은 ‘나쁜 관행’의 의미와 기준을 밝힌다(IV-2). 그리고 ‘나쁜 관행’에 대해서는 그것에 따를 준수 의무를 부정하며, 나쁜 관행의 처리와 해결법을 논한다(IV-3). 마지막으로 본고의 법학적 관행 이론과 대안적 법관행주의의 상호 관계 및 전망을 언급하며 글을 맺는다.

3. 규범성 탐구를 위한 방법론적 전제

본고의 ‘법학적 관행 이론의 세 단계’는 ‘규범성 담론의 세 차원’과의 연계 속에서 구상한 것이기에 탐구의 각 단계마다 일정한 방식으로 관행의 규범성 문제가 결부되어있다. 따라서 본격적인 논의에 앞서 규범성 탐구를 위한 방법론적 전제들을 살펴보고 유념할 필요가 있다. 첫째, 규범성에 관한 물음¹³⁾을 구체화 할 필요가 있다. 규범(성) 개념은 외연이 매우 방대하기 때문에 연구자의 인식관심과 실천적 지향에 따라 연구 범위와 방향을 명확히 해야한다.¹⁴⁾ 둘째, 적절한 ‘관점’과 ‘인칭’ 채택이 중요하다. 규범성 물음을 다루기

13) 코스가드는 ‘규범성에 관한 물음’을 도덕이 우리에게 요구하는 바에 대한 정당화 근거를 고찰하는 것으로 정의한다. Christine M. Korsgaard(강현정 · 김양현 옮김), 『규범성의 원천』, 철학과 현실사, 2008, 29면.

14) 본고에서 필자가 해명하고자 하는 ‘관행의 규범성에 관한 물음’은 다음의 두 차원과 연결된다. ① <존재론적 규범성론>: 분류 · 분석적 차원: 규범성의 존부와 특성 해명, ② <가치론적 규범성론>: 평가 · 정당화 차원: 규범성의 원천과 나쁜 관행의 효력과 처우 문제가 그것이다. 이 구분에 따르면, 본고 III은 ①을, IV는 ②의 문제를 주로 다룬다. 관행의 규범성을 첫 번째 차원에서 상세히 고찰한 글로는 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰,” 『법학논총』 제34집 제3호, 한양대학교 법학연구소, 2017 참고.

위해서는 일인칭 참여자의 관점, 즉 관행 당사자들의 내적 관점을 채택해야 한다. 왜냐하면 관행이란 그것의 형성과 발전, 작동기제 상 그 규범과 분리되어 철저히 초연한 판단(detached judgement)을 행하는 외부 관찰자의 관점에서 해명되기 어려운 면이 있기 때문이다. 셋째, 관행의 규범성¹⁵⁾은 ‘이유에 기반한 접근(reason-based approach)’¹⁶⁾을 통해 행위자의 실천적 추론의 차원에서 가장 잘 파악될 수 있다.¹⁷⁾¹⁸⁾

II. 〈1단계〉: ‘법적 관행’의 개념과 요건

1. 루이스의 관행 이론 검토

기존의 사회적 관행 이론의 발전 양상은 크게 세 흐름으로 정리할 수 있다.

- 15) ‘관행의 규범성’ 문제는 고전적인 철학적 주제 중 하나이며, 이 문제에 접근하는 다양한 방식이 있다. 예컨대 ‘존재·당위 이원론(흄), 자연주의적 오류(무어), 사실적인 것의 규범력(엘리네크), 최근에는 제도적 사실 이론(셀, 맥코믹 등), 내재적 실재론(윌리엄스)과 같은 이론들이 밀접하게 관련되어 있다. 하지만 본고에서는 기존의 철학 논쟁을 직접적으로 다루지는 않으며, 필자의 문제의식을 기초로 관행 이론들의 주안점을 중심으로 논의 범위를 제한한다.
- 16) ‘이유에 기반한 접근’은 두 가지 함의를 갖는다. 우선 전통적 논증 방식인 존재론적 접근을 택하지 않음을 의미한다. 더 적극적으로 말하면, 결국 (넓은 의미에서) 법적 판단과 결정이라는 것은 실천적 추론의 과정에서 이루어지는 것이기에 그런 맥락 안에서 작동하는 이유(reason) 중심의 논의가 더욱 유용할 것이다. 라즈도 이런 접근을 하는데, 모든 종류의 ‘규범적인 것(the normative)’의 규범성은 이유와 관계된다고 설명한다. Joseph Raz, “Explaining Normativity: On Rationality and the Justification of Reason,” in *Normativity*, Blackwell, 2000, pp.34-35.
- 17) 이 주장은 다음의 물음들로 구체화할 수 있다.: ① 관행은 행위 이유를 제공하는가? (‘**이유 제공적 특성**’) ② 관행은 행위 향도 기능을 하는가? (‘**행위 향도적 특성**’) ③ 관행은 준수 의무를 창출하는가? (‘**채무 산출적 특성**’) (①과 ②는 사실상 통합되어 있다.) ‘관행 규범성의 구조’를 형성하는 이 요소들은 단계적으로 상호 연관된 상승구조를 이룬다. 이런 인식구조를 전제할 때 관행이 제공하는 이유의 성격, 채무 산출력의 존부와 근거 등이 섬세하게 검토될 수 있다. 이 점은 본고 제Ⅲ장 ‘관행의 규범적 위계 및 규범력의 정도’에서 상세히 다루어진다.
- 18) 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰,” 264-267면.

관행을 조정 문제에 대한 해법으로 규정한 흄(David Hume)과 루이스(David Lewis)의 ‘조정 해법 모델’, 루이스 이론의 근본 전제를 거부하며 등장한 ‘대항 모델’,¹⁹⁾ 그리고 조정 해법 모델을 수용하지만 다른 유형의 관행(구성적 관행)을 제시한 마머(Andrei Marmor)의 ‘복합적 관행 모델’이 있다.²⁰⁾ 이 중 루이스 이론은 현대 관행 이론 지형을 바꾼 전환점을 제공하여, 후대의 관행 이론들은 대부분 그에 대한 비판이나 옹호를 중심으로 다양한 분야에서 발전되어왔다. 따라서 대안 이론 구상을 위한 출발점이자 닳으로 삼기에는 루이스의 이론이 적합할 것이다.

루이스²¹⁾는 최초로 관행 개념에 대한 철저한 분석을 제공하여 관행 이론의 새 지평을 열었다.²²⁾ 루이스는 관행이란 전략적 상호작용에 관여된 합리적 행위자의 실천적 추론 안에서 그것이 수행하는 기능을 통해 가장 잘 이해될 수 있다고 설명한다.²³⁾ 루이스는 관행 개념을 행위의 정규성(regularity), 상호 기대 및 선호의 체계로 구성한다. 다음은 루이스의 최종 관행 정식이다.²⁴⁾

19) 예컨대 Margaret Gilbert, Seumas Miller, Ruth Millikan 등.

20) 이에 관한 자세한 설명은 이현경, “사회적 관행 이론의 세 모델: 비판적 검토,” 『법학논집』 제21권 제3호, 이화여자대학교 법학연구소, 2017 참고.

21) 루이스의 문제의식의 시작점은 “언어가 관행적이다”라는 상투어에 대한 콰인의 회의주의적 반론에 대해 방어 가능한 대안적 관행 이론을 구축하는 데 있었다. 이를 위해 그는 흄의 기본적 관점과 결론(‘관행은 공동 이익에 대한 일반적 감각’)을 순수 조정 게임 이론의 틀과 결합하였고, 양자를 이론적 기반으로 삼는다. Lewis, *Convention*, p.3.

22) 골도니는 “법관행주의 학파의 첫 번째 물결(the first wave)은 루이스의 저서 *Conventions*의 출판 이후에 등장했다.”고 평한다. Marco Goldoni, “Multilayered Legal Conventionalism and the Normativity of Law,” in *New Essays on the Normativity of Law*, Hart Publishing, 2011, p.159.

23) Lewis, *Convention*, p.33.

24) 루이스의 관행 이론은 최종 관행 정식에 이르기까지 4단계의 변천 과정을 거친다; (A) 최초의, 투박한 정의(Lewis, 위의 책, p.42.) ⇒ (B) 관행 존재를 위한 정의적 조건: 예외 없이 적용되고, 완벽한 관행 사례에 맞춰진 정의(Lewis, 위의 책, p.58.) ⇒ (C) 수정된 정식: 예외를 허용, 개연성(Lewis, 위의 책, p.76) ⇒ (D) 최종 정의(Lewis, 위의 책, p.78) 이현경, “사회적 관행 이론의 세 모델: 비판적 고찰,” 204면, 각주 24.

일정 규모의 인구집단 P(Population)의 구성원들이 반복적으로 야기되는 상황 S에 위치한 행위자일 때 그들의 행동으로부터 규칙적으로 일어나는 현상 R(Regularity, 이하 ‘정규성’)은 만일 P의 성원들 가운데 S의 어떠한 상황 하에서도 다음과 같은 사실이 참이고 또한 P의 사회에서 공통 지식(common knowledge)인 오직 그 경우에만 관행이 된다.

- (1) 거의 모든 사람들이 R을 준수한다.
- (2) 거의 모든 사람들이 자기 이외의 거의 모든 사람들이 R을 준수하기를 기대한다.
- (3) 거의 모든 사람들이 행위의 모든 가능한 조합들에 대해 대략 같은 선호를 갖는다.
- (4) 거의 모든 사람들은, 거의 모든 사람들이 R을 준수한다는 조건 하에서 누구라도 R을 준수하기를 선호한다.
- (5) 거의 모든 사람들이 R*를 준수한다는 조건 하에서라면, 거의 모든 사람들은 누구라도 R*를 더 많이 준수하기를 선호할 것이다.

S에서 P의 구성원의 행위 안에서 R*가 가능한 정규성이면, P의 구성원들 사이에서 S의 그 어떤 상황에서도 어느 누구도 R*와 R을 동시에 준수할 수 없다.²⁵⁾

루이스의 관행 이론의 가장 큰 업적은 ‘관행적인 것(the conventional)’이라는 상투어의 특별한 의미를 규명한 데 있다. 첫째, 관행은 동등하게 좋은(equally good) 가치를 갖는 대안 규칙의 존재를 반드시 요한다는 점에서 ‘임의적(arbitrary)’이다.²⁶⁾ 둘째, 우리가 관행에 따르는 주된 이유는 “대부분의 사

25) Lewis, *Convention*, p.78. 본고에서는 루이스 정식의 각 요건에 대한 상세한 설명은 생략하고 간략한 논평으로 대신한다. 본고의 ‘법적 관행 정식’(대안 정식)은 기본적으로 루이스 정식을 수정·보완한 것이기에, 대안 정식의 요건을 설명하는 것으로 갈음한다. 다만 루이스 정식과 필자의 대안 정식의 각 요건 및 용어 사용의 차이점에 주목할 필요가 있다. 이는 결국 관행 개념과 본질에 대한 상이한 개념관(概念觀)으로 귀결되기 때문이다.

26) ‘임의성’의 의미에 대해서는 논자마다 견해가 다르다. 필자는 ‘동등하게 좋은 대안이 존재함’이라는 루이스의 해석을 수정하여 대안 정식에 반영하였다. 이에 관해서

람들이 그렇게 행하기 때문”이라는 ‘일반적 준수 의존성’에 있다. 필자는 이 두 가지가 ‘관행성’을 이루는 필수 요건이며, 이 점을 인정할 때 관행이 다른 규범과 구별되는 특별함을 보존할 수 있다고 본다. 하지만 루이스의 관행 정식은 게임 이론의 언어와 틀을 기초로 정립된 것이어서, 현실의 다종다기한 사회적 관행, 특히 법적 관행의 실재를 해명하기에는 근본적 한계가 있다.²⁷⁾

게임이론에 기반한 조정 관행 모델은 관행의 본질을 ‘내쉬 균형(nash equilibrium)’²⁸⁾으로 규정한다. 내쉬 균형이란 그 어떤 행위자도 그것으로부터의 단독적 이탈을 통해 자신의 보수가 더 증진될 수 없는 균형점을 말한다. 즉 균형점을 벗어나서 행동하면 결국 자기만 손해라는 것이다. 따라서 내쉬 균형에서는 어느 누구도 관행에서 단독으로 이탈할 합리적 이유가 존재하지 않고, 그 결과 내쉬 균형은 자력으로 시행을 강제하는(self-enforcement) 특징(‘자기-강제성’)을 가지며,²⁹⁾ ‘안정성’과 ‘자기-영속성’을 확보할 수 있게 된다.

하지만 이런 설명은 비현실적이다. 사회적 삶과 현실의 조정 문제는 게임 이론에서 상정하는 것만큼 단순하지 않으며, 관행에의 참여자들 역시 게임 경기자들처럼 자유롭고 평등한 합리적 주체라는 보장이 없다. 현실에서는 관행을 둘러싼 관련 당사자들 간에 모종의 도덕적·정치적 권력의 불균형 상태가 흔한데, 루이스 이론 안에서는 그러한 비대칭성과 복잡성, 위계 등은 고려되지 못한다. 만약 루이스적 관행 이론을 법적 영역에 그대로 차용한다면, 이런 점은 중대한 결함으로 작용할 것이다. 또한 루이스는 관행의 본질과 기본 단위를 ‘행위 정규성’으로 규정함으로써, 사회적 관행의 본질적인 규범적 특

는 ‘법적 관행 정식’(II-2.) 부분에서 후술한다.

27) 게임 이론에 기반한 루이스 식 조정 관행 모델의 특징과 한계를 지적한 글로는, 이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요소: 관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초,” 『법철학연구』 제20권 제1호, 한국법철학회, 2017 참고.

28) ‘내쉬 균형’이란 수학자 존 내시(John F. Nash)가 창안한 개념으로, 게임이론에서는 다음과 같이 정의된다. “정규형 게임에서 각 플레이어가 목록에 있는 다른 전략들에 대한 최선반응인 1개의 전략을 갖는다면 그러한 전략의 목록이 내시 균형이다.” Roger A. McCain(이규익 옮김), 『게임이론』, 시그마프레스, 2013, 53면.

29) Gerald J. Postema, “Conventions at the Foundation of Law,” in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Peter Newman (Ed.), 1998, p.468.

성을 제대로 담아내지 못한다. 이는 경험적 차원에서 보더라도 규범성을 필
 함하는 법적 관행의 실재와 괴리가 있다.

요컨대 게임 이론에 기반한 루이스의 관행 정식은 사회적 관행에 관한 ‘일
 반 이론’의 차원에서 그 실재를 충분히 담아내지 못한다. 또한 ‘범이론’의 차
 원에서 보더라도 특히 관행의 본질적인 규범성을 간과한다³⁰⁾는 점에서 문제
 가 있다. 따라서 이러한 한계를 보완하고 적절히 개선한 ‘법적 관행’ 개념과
 대안 이론이 필요하다.

2. ‘법적 관행’의 개념과 ‘관행성’의 본질

(1) ‘법적 관행 정식’(이하 ‘대안 정식’으로 약칭함)

‘법적 관행(legal convention)’은 ‘사회적 관행’의 특별한 한 유형이다. 따라서
 필자는 기존의 사회적 관행 이론들이 ‘일반적인 관행 이론’의 차원에서 보이
 는 한계를 보완하고, ‘법적’ 측면을 구체화하는 요건을 추가하여 ‘법적 관행
 정식’을 다음과 같이 제안한다.

[표 2] 법적 관행 정식

■ 다음의 조건들이 획득되면, 어떤 규칙 R은 법적 관행이 된다.

- (1) R은 특정한 목표(point)나 가치(value)를 전제로 하는 협력적 실천으로,
- (2) 일정 규모의 집단 P의 구성원들에게는 상황 C 하에서 R을 준수할 이유
 혹은 이유들의 조합 A가 존재하지만, R에의 준수 이유나 결의가 참여자들
 에게 반드시 명확하게 인식/공지될 필요는 없다.
- (3) P의 구성원들은 어떤 상황 C에서 공동체 내 다른 사람들의 일반적 준수
 를 조건으로 대부분의 사람들이 규칙 R을 준수하기를 선호하리라 기대하
 며, 일반적 준수에 대한 정당한 기대를 조건으로, 대부분의 사람들이 R을

30) 루이스도 이 점을 스스로 인정한다. “내가 관행에 대해 제시했던 정의는 규범적
 용어들(“ought”“should”“good”등)을 포함하지 않았다. (...) 따라서 “관행” 그 자체
 는 나의 분석에서는 규범적 용어가 아니다. 그럼에도 불구하고 관행은 규범의 한
 종류가 될 수도 있다: 누군가 그것을 준수해야만 한다고 우리가 믿는 정규성.”
 Lewis, *Convention*, p.97.

준수한다.

- (4) 하나 이상의 잠재적인 규칙 R^* 가 존재하며, 만약 상황 C에서 P의 구성원들이 실제로 R^* 를 준수한다면, 이 사실은 R 대신에 R^* 를 준수할 충분한 이유가 된다. 다른 조건들이 동일하다면, 상황 C에서 R과 R^* 를 동시에 준수하는 것은 불가능하거나 무의미하다.
- (5) ① 관행에 관여된 행위자 중 일부가 법체계상 공적인 지위를 갖거나 그러한 역할과 연관되는 경우, ② 관행이 헌법적 사항을 규율하는 경우, ③ 관행이 법규범에 의해 제도적으로 지지를 받는 경우[관행이 법규범에 의해 창출되고 인정된 경우], ④ 그것이 만약 분쟁화 되었을 때 관계인의 직접적인 법적 권리·의무 관계로 전이될 가능성이 큰 경우 이는 ‘법적 관행’으로 인정된다.
- (6) R은 그것의 생성/소멸에 있어 명시적 합의/약속 등의 시점적 절차를 요하지 않으며, 정규성의 경우에도 단선적인 시간 지속성은 요하지 않는다.

위 정식의 각 조건을 충족한 관행은 ‘진성의 법적 관행(genuine legal convention)’으로서 모종의 규범력을 가지며, 법질서 안에서 일정한 법적 위상을 획득한다. 대안 정식을 구성하는 각 조건을 중심으로 ‘법적 관행’의 개념과 본질을 이해해보자.³¹⁾

첫째, (조건 0): ‘규칙-규범’ 요소: “다음의 조건들이 획득되면, 어떤 규칙 R은 법적 관행이 된다.” 이 정식에서 관행을 이루는 기본 단위는 ‘규칙(rule)’이다. 루이스는 관행의 기본 단위와 본질을 행위 ‘정규성(regularity)’으로 보지만, 대안 정식에서는 ‘규칙’으로 재규정함으로써 우리는 자연히 관행의 규범성, 특히 관행의 효력과 준수의무의 문제를 논할 수 있게 된다. 관행 준수는 ‘규칙 준수하기’의 문제³²⁾이며, 이 점이 관행의 규범성을 인식하는 출발점이 된다.³³⁾

31) 대안 정식의 각 요건에 대한 상세한 설명은 이현경, “법적 관행의 개념과 그 요건,” 『법학논총』 제37권 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2017 참고.

32) 마머는 규칙 준수하기라는 발상은 빈번함(frequency)을 요하지 않는다고 말한다. 규칙과 행위 정규성의 차이에 관한 마머의 설명은, Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory*, Oxford University Press, 1992, pp.41-42 참고. ‘규칙 준수하기(rule-following)’와 규범성의 문제를 다각도로 다루고 있는 최근 문헌으로는, Muchal Araszkievicz · Pawel Banas · Tomasz Gizbert-Studnicki · Pleszka Krzysztof (Eds.), *Problems of Normativity, Rules, and Rule-Following*, Springer, 2015.

둘째, (조건 1): ‘목표나 가치, 협력적 실천’ 요소: “R은 특정한 목표(point)나 가치(value)를 전제로 하는 협력적 실천으로”라는 규정은 다음의 점을 함축한다. 우선 관행은 그 본질이 조정 문제 해결이라는 ‘조정 해법 모델’에 한정되지 않는다. 관행은 공동의 사회적 삶 속에서 어떤 목표나 가치, 필요 등에 대한 모종의 규범적 응답으로, 그러한 가치 실현에 기여한다. 예컨대 한줄서기나 선착순은 평등주의 이념을, 야구의 불문율은 스포츠 정신의 구현을 목표로 한다. 만약 그 질서가 전제하고 있는 가치를 발견할 수 없다면 이는 진정한 의미에서 관행이 아니다. 가치나 목표는 꼭 도덕적일 필요는 없지만 합당하게 수용할 만한 것으로서 최소한 중립적이다. 또한 관행은 각자의 사익 실현을 넘어 평온한 공존을 위한 협력적 실천의 속성을 갖는다.³⁴⁾ 협력이란 기본적으로 선(善)의 가치를 지향하는 것인데, 본 정식에서 이 요소는 소극적으

33) “관행이 규칙의 일종이라는 점을 깨닫지 못한 것이 수많은 혼란을 야기해왔다. 행위의 정규성, 다시 말해 한 사람의 정규성이든 여러 사람들에 의해 공유되는 정규성이든 그것은 결코 규칙 따르기의 예가 아니다. 그리고 만약 그렇지 않다면, 그것은 관행의 문제 역시 될 수 없다. 이 점을 깨닫지 못하는 것은 관행의 규범적 측면에 대해 생각하지 못함으로써만 발생할 수 있다.” Andrei Marmor, “On Convention,” *Synthese*, Vol. 107, No. 3, 1996, p.353(밑줄은 필자).

34) ‘대안 정식’에서 특정 가치에 봉사하고 평온한 공존을 위한 협력적 이상을 전제한다는 이 요건은 평가적 차원, 혹은 가치론적 규범성론의 관점에서 보면 적어도 세 가지 점에서 중요한 기능을 한다. 첫째, 악의적이거나 명백히 부도덕한 목적을 위한 수단적 차원에서의 조정 활동을 걸러내는 여과장치 역할을 한다. 이 견해에 따르면, 가령 범죄의 완수를 위한 공모공동정범 간의 공동의 실천은 가치에 기반한 것이 아니라는 점에서도 관행이라고 볼 수 없다. 그것은 ‘조정 균형’일 수는 있지만 ‘관행’이라고 보기는 어렵다. 왜냐하면 적극적 차원에서 논해지는 가치는 개념 정의상 부정적인 것일 수는 없기 때문이다. 둘째, 관행의 임의성은 종종 극단화 되거나 부정적인 방향으로 변질될 수 있다. 그런 경우 조건 (1)은 현재의 관행이 애초에 그것이 기여하고자 했던 가치에 여전히 부합하는지를 기준으로 그 타락을 규율하거나 평가하는 내적 제어장치 역할을 할 수 있다(‘합목적성 심사’). 다만 이는 형식주의적 관점에 그치며, ‘나쁜 관행’을 전부 가려내고 평가할 만큼 충분한 역할을 하지는 못한다. 셋째, 가치나 목적에 관한 해석은 가변적이기에, 기존 관행의 품질도 그와 같은 해석 변화에 맞추어 재평가될 수 있다. 따라서 어떤 질서를 현재적 관점에서 외적 기준(예컨대 비판도덕 등)에 따라 ‘나쁜 관행’이라고 판정하기 전에, 관행 개념론 안에서 그 자체의 변화 가능성을 어느 정도 포용할 수 있는 것이다. 조건 (1)이 바로 그것을 가능하게 하는 개념 장치라고 볼 수 있다. ‘나쁜 관행’의 문제에 관해서는 본고 IV장에서 상술한다.

로만 기능한다. 그리고 가치나 목적, 취지의 내용에 대한 해석은 변할 수 있기에 그것의 실현에 복무하는 관행의 내용 역시 고정되지 않는다.³⁵⁾ 이는 관행의 동적 특성³⁶⁾의 일면을 담고 있다.

셋째, (조건 2): ‘준수할 이유 있는 규칙, 불투명성’ 요소: “일정 규모의 집단 P의 구성원들에게는 상황 C 하에서 R을 준수할 이유 혹은 이유들의 조합 A가 존재하지만(2-1), R에의 준수 이유나 결의가 참여자들에게 반드시 명확하게 인식/공지될 필요는 없다(2-2).” 관행은 그것에 준수할 이유가 있는 규칙이다. 전항 (2-1)은 각자가 관행을 준수할 이유나 이유의 조합은 다를 수 있음을 함축한다. 후항 (2-2)는 ‘불투명성(opaqueness)’을 의미한다. 즉 각자는 관행을 준수하는 나름의 이유를 갖지만 그것이 다른 사람들에게 반드시 공지될 필요는 없다. 관행 참여에의 결의 역시 ‘공통 지식(common knowledge)’이 되기를 요하지 않는다.³⁷⁾ 이는 관행의 ‘존재·성립 조건’이 아닌, 강력한 관행을 만드는 ‘강화 조건’일 뿐이다.³⁸⁾ 또한 사람들은 자신이 준수하고 있는 것이 관행 규칙이라는 사실을 명확히 자각할 필요는 없지만 그에 대한 잠재적인

35) 예컨대 야구에서 불문율은 스포츠 정신의 구현을 위한 것이다. 그런데 ‘스포츠 정신’의 내용에 대한 해석은 시·공간에 따라 다를 수 있다. 가령 과거에는 ‘공정한 경기 운영과 선수 보호’가 스포츠 정신의 본령이었다면 현재는 ‘포기하지 않는 불굴의 도전정신’으로 바뀌었다는 주장도 가능하다.

36) 필자는 기존의 주류적 관행 이론들은 관행을 정적인 고정체로 파악한다는 점에서 ‘정적 관행 이론’으로 분류한다. 이는 관행의 실제에서 파악되는 ‘역동성’을 제대로 다루지 못한다. 따라서 필자는 대안 이론이 추구하는 한 측면으로 관행에 대한 동적 접근을 강조한다. 이에 관해서는 이현경, “동적 관행 이론,” 『강원법학』 제51권, 강원대학교 비교법학연구소, 2017 참고.

37) 이런 점에서 본고의 ‘대안 정식’은 루이스의 모델과 차이가 있다. 루이스는 ‘공통 지식’을 관행 존재의 필수 요건으로 포함시킨다. Lewis, *Convention*, p.78. 관행과 공통 지식의 관계에 관한 글로는 특히 Giacomo Sillari, “Common Knowledge and Convention,” *Topoi*, Vol. 27, 2008; Ken Binmore, “Do Conventions Need to Be Common Knowledge?,” *Topoi*, Vol. 27, 2008; Peter Vanderschraaf and Giacomo Sillari, “Common Knowledge,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2013.

38) 필자는 사실적으로나 규범적으로 강력한 관행을 만드는 ‘강화 조건’으로 ① 공통 지식과 공식적 표명, ② 시간적 지속과 반복, ③ 제도적 지지, ④ 도덕적 이유들을 주장한다. 이에 관한 설명은 본고 III-1. 참고.

인식은 있어야 한다.³⁹⁾

넷째, (조건 3): ‘준수 의존성’: “P의 구성원들은 어떤 상황 C에서 공동체 내 다른 사람들의 일반적 준수를 조건으로 대부분의 사람들이 규칙 R을 준수하기를 선호하리라 기대하며, 일반적 준수에 대한 정당한 기대를 조건으로, 대부분의 사람들이 R을 준수한다.” 우리는 관행의 내용이 도덕적으로 옳거나 바람직하거나 효율적이라는 등의 어떤 실질적인 내적 장점 때문에 따르는 것이 아니다. 관행 준수의 주된 이유는 어떤 이유에서건 거의 대부분의 사람들이 그것을 준수하며, 그러한 전제 하에 서로가 준수하고자 기대한다는 사실에 있다. 그런데 이 ‘준수 의존적 이유’는 필수적이긴 하지만 관행에 따를 이유의 일부가 될 뿐이다.⁴⁰⁾ 또한 ‘일반적 준수’란 반드시 시간적 혹은 수적인 면에서의 양적 기준을 뜻하지 않는다.⁴¹⁾ 가령 ① 설사 단기간일지라도⁴²⁾ ② 그 공동체의 일선에서 체계의 유지와 존속에 결정력 있는 권한을 갖고 제도적 헌신의 정도가 큰 참여자들이 ③ 그 현저성(salience)에 대한 상호 승인과 신뢰에 기초하여 형성한 균형점을 ④ 책임감 있게 준수한다면 이 조건을 충족한 것으로 볼 수 있다.

다섯째, (조건 4): ‘임의성’ 요소: “하나 이상의 잠재적 규칙 R*가 존재하며, 만약 상황 C에서 P의 구성원들이 실제로 R*를 준수한다면, 이 사실은 R 대신에 R*를 준수할 충분한 이유가 된다. 다른 조건들이 동일하다면, 상황 C에서 R과 R*를 동시에 준수하는 것은 불가능하거나 무의미하다.” ‘임의성

39) 마머 역시 같은 설명을 한다. “관행을 준수하면서 자신이 행하고 있는 것이 규칙을 따르는 것이라는 점에 대한 잠재적 인식이 항상 있다. 하지만 그 규칙을 위한 이유가 무엇인지 또는 그것이 어떤 종류의 규칙인지를 행위자가 반드시 알아야 하는 것은 아니다.” Andrei Marmor, *Social Conventions: From Language to Law*, Princeton University Press, 2009, p.7.

40) “부분적 이유가 된다”는 것은 개별 행위자마다 각자 나름의 경제적 이유, 도덕적 이유, 타산적 이유 등이 얼마든지 결합될 수 있음을 뜻한다. 여기서의 핵심은 그 중 가장 주된 이유의 본질이 ‘준수 의존적 이유’라는 점이다.

41) 반면에 마머는 ‘상당수의 사람들의 사실상의 준수’를 요한다. 이점에서 본고의 대안 이론과 차이가 있다. 이에 관한 분석과 논평은 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 122-126면 참고.

42) 시간적 기준과 관련해서 본다면 최근 국제법 영역에서 공식적 법원(法源)으로 논의되는 ‘인스턴트 관습법’도 이런 관점에서 재해석될 수 있다.

(arbitrariness)’이란 증대한 비용이나 손실의 부담 없이 현재의 관행이 추구하는 가치나 목표를 실현할 수 있는 대안 규칙이 존재함을 뜻한다. 루이스의 표현을 빌리자면, “만약 대안 관행이 없다면 그것은 조정 균형이긴 하더라도 진성 관행은 아닌 것”⁴³⁾이다. ‘대안 정식’에는 여기에 세 가지 단서가 추가된다. 첫째, 관행 R에 대한 잠재적 대안이 되는 규칙 R*가 ‘그렇게 행하지 않음’이 될 수는 없다.⁴⁴⁾ 만약 ‘그렇게 행하지 않음’을 대안 규칙으로 인정한다면 임의성 요건은 사실상 무의미해지며 관행 개념의 외연이 과도하게 확장되기 때문이다.⁴⁵⁾ 둘째, ‘임의성’은 제멋대로 변덕스럽게 들쭉날쭉하다는 어감을 갖는 ‘자의성’과 다르다. 관행은 임의적이긴 하지만 나름의 규칙성과 내적 논리를 갖고 있다. 또한 가능한 대안들 사이에 선호의 우위가 존재하지 않는다는 ‘선호의 무차별성’이나 ‘무관심’을 함축하지 않는다.⁴⁶⁾ 관행에의 참여자는 각자의 사적 선호가 있더라도 현저성이 승인된 실제 관행을 준수함으로써 공동 목표나 가치가 실현되기를 더 바란다는 것이 핵심이다. 셋째, 임의성은 ‘도덕적 무차별성(morally indifference)’을 함축하지 않는다. 말하자면 대안 규칙은 실제(actual) 관행과 도덕적으로 동등한 가치를 갖는 것일 필요는 없다. 해당 관행이 전제하는 가치, 목표, 필요를 구현하고 응답하는 균형점이면 족하다. 바로 이 점 때문에 ‘나쁜 관행’의 존재 가능성이 논리적으로 가능하며 개념론적으로 해명될 수 있다.

여섯째, (조건 6): ‘비공식성, 불연속성의 허용’ 요소: “R은 그것의 생성/소멸에 있어 명시적 합의/약속 등의 시점적 절차를 요하지 않으며(6-1), 정규성

43) Lewis, *Convention*, pp.45-46.

44) 마머 역시 같은 취지의 주장을 한다. Marmor, *Social Conventions*.

45) 필자는 바로 이 점에 근거하여 ‘여성 할례 사례’의 관행성을 부정한다. 즉, 여성할례는 자격을 갖춘 대안 규칙이 존재하지 않기에 임의성 요건을 충족하지 못하고, 따라서 관행이 아니다. (그 내용이 부도덕하기 때문에 관행 자격성을 부정하는 논변이 아님에 유의할 필요가 있다.)

46) ‘임의성’이 ‘선호의 무차별성’을 함축하지 않는다는 의미는 다음과 같다. 예컨대 한국에서는 충돌방지를 위해 우측주행 관행을 갖고 있다. 그런데 만약 동일한 이유로 사람들이 실제 좌측 주행을 한다면, 사람들은 우측주행 규칙을 따를 충분한 이유를 갖게 된다. 하지만 이 점이, 예컨대 물리적으로 그것이 더 편리하다고 생각되기 때문에 사실상 대부분의 수법자들이 우측주행을 더 선호한다는 가능성을 배제하지는 않는다.

의 경우에도 단선적인 시간 지속성은 요하지 않는다(6-2).” 이 조건은 관행의 성립요건이라기 보다는 일종의 단서 조항이다. (6-1)은 관행이 자발적 질서임을 뜻한다. 본연적 의미에서의 관행은 자생적인 묵시적 규범질서⁴⁷⁾로, 특정 시점에서의 명시적인 입법적 활동이 없이도 자연스러운 발생과 소멸의 과정을 거친다. 그러나 설사 관행 형성에 있어서 의도적 계기나 이슈 메이커의 유권적 개입이 있더라도 그것의 관행 적격성이 부정되는 것은 아니다.⁴⁸⁾ 약속이나 공식적 합의도 관행 형성의 기원이 될 수 있다.⁴⁹⁾ 중요한 것은 그 질서가 자율적 메커니즘에 의해 존속·발전되어간다는 점이다. 조건 (6-2)는 행위 정규성으로부터 관행이 성립된 경우에도 반드시 장기간 중간 단절 없이 지속되기를 요하지 않음을 뜻한다. 즉 압축적인 일회·반복성이 허용된다.⁵⁰⁾ 중요한 것은 ‘단절 없는 장기간의 행위 정규성’이 아니라 ‘현저성(salience)’이며, 인식적 차원에서의 ‘예측 가능성 보장’과 ‘사실적인 기계적 안정’의 보장보다는 ‘상호 의존적 신뢰(mutual reliance)’의 보호와 ‘합당한 안정성’이라는 것이 필자의 주장이다.

마지막으로 (조건 5)는 ‘법적’을 구체화하는 기준들을 의미한다. 어떤 규칙이 ‘사회적 관행 정식’(조건 5를 제외한 나머지)을 충족하면서 동시에 다음 항목 중 하나 이상을 포함하면 ‘법적 관행’으로 인정된다. 구체적으로는 ① 관행의

47) ‘규범적 질서’의 특징에 관해서는 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰,” 제II장; 이현경, “제도적 사실로부터 제도적 규범질서로: 맥코믹의 제도적 법 개념 발전과정과 변천에 관한 고찰,” 『법학논총』 제30권 제2호, 국민대학교 법학연구소, 2017 참고.

48) 가령 한국에서 ‘에스컬레이터 한줄서기’ 관행의 형성 계기가 사실상은 1988년 올림픽을 앞두고 국가의 정책적인 캠페인 활동을 통해 촉구되었다는 사실을 예로 들 수 있다. 여기서 필자의 주안점은, 이런 점이 그 질서의 관행성을 박탈하는 이유가 되지 않는다는 점을 논증하는 것이다.

49) “관행은 두 기원을 갖는다. 일부 관행은 자발적 질서로서 당사자들의 자율적인 상호작용을 통해 생겨나며, 또 일부는 중앙의 조정자나 권위적 기구의 개입을 통해 부여되기도 한다.” 러셀 하딘 (황수익 옮김), 『집합행동』, 나남출판, 1995, 297면.

50) 이 조건은 특히 ‘관행’과 ‘관습’ 개념을 구별하는데 있어서 중요한 역할을 한다. 필자는 “관습(custom) ≡ 관행(convention) * 습관화(habitation)”의 개념 도식을 주장한다. 이에 관한 설명은, 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 223-230면 참고.

형성과 실행에 관여된 행위자 중 일부가 법체계상 공적인 지위를 갖거나 그러한 역할과 연관된 경우: ‘**법 공직자 관행**’, ② 관행의 내용이 헌법적 사항을 규율하는 경우: ‘**헌정 관행**’,⁵¹⁾ ③ 관행이 법규범에 의해 창출되고 인정된 경우: ‘**실정법적 관행**’(최협의의 법적 관행),⁵²⁾ ④ 관행이 만약 분쟁화 되었을 때 관계인의 직접적인 법적 권리·의무 관계로 전이될 가능성이 큰 경우: ‘**전이된 법적 관행**’이 그것이다.⁵³⁾

(2) ‘관행성’과 ‘규범성’ 간의 긴장관계

그렇다면 위의 조건들 중에서 관행을 관행이게끔 하는, 즉 ‘관행성(conventionality)’의 본질을 이루는 요건은 무엇일까? 관행인지 아닌지를 판별하는 기준이자 본성으로서 ‘관행성’을 규정짓는 필수 요소는 ‘임의성’과 ‘준수 의존성’이다. 본고의 대안 정식에 따르면 ‘임의성’의 최소 기준은 ① 인식 가능한 대안이 존재함과 ② 관행에 따를 주된 이유의 본질이 준수 의존적 이유라는 점이다.⁵⁴⁾ 또한 ‘일반적 준수 의존성’도 관행성을 보증하는 핵심 요건이

51) ‘헌정 관행(conventions of the constitution; constitutional conventions)’은 국가 운영이나 헌법적 사항을 규율하는 관행을 가리킨다. 이는 주로 영국에서 형성된 개념인데, 우리 사회에서도 공론화된 적이 있다. 대표적인 예로, 한국 정치사에서 있었던 ‘대통령 국무 총리 서리’ 제도에 대한 정치적, 헌법학자들 간의 논쟁이 있다. 자세한 사항은 정종섭, “대통령의 국무총리 임명에 대한 국회의 동의,” 『헌법학연구』 제4권 제2호, 참고. 또한 관습헌법론 역시 대안 정식의 분류에 따르면 ‘헌정 관행’과 밀접히 관련된다. 영국에서의 헌정 관행에 관해서는 김기창, “성문헌법과 ‘관습헌법,’” 『공법연구』 제33집 제3호, 2005 참고.

52) 사회적 관행은 종종 법규범에 의해 제도적으로 지지되고, 일부는 아예 법규칙으로 승격되기도 한다. 비공식적 규범질서로 존재해온 관행이 법규칙이나 법원칙을 통해 실정법으로 승격됨으로써 일종의 ‘실정법적 관행’이 되는 것이다. 법규칙을 통한 예로는 ‘관행어업권’이나 ‘권리금’이 있다. 1990년 개정 전 구(舊) “수산업법” 제40조의 1항(입어의 관행)은 종래의 입어 관행을 성문화함으로써 입어 관행을 법적 권리로 승격시켰다. 그리고 기존에 관행상 인정되어오던 상가 권리금 수수 관행이 2015년 5월 “상가건물 임대차보호법”의 개정을 통해 ‘권리금 계약’으로 법제화된 사례도 있다. 본고의 법학적 관행 이론에 따르면 이러한 사례는 관행이 ‘입법적 체계화’를 통해 제도적으로 승격된 경우이자 ‘실정법적 관행’의 한 예로 볼 수 있다.

53) ‘법적’ 요건을 구체화한 (조건 5)에 관한 자세한 설명은 이현경, “법적 관행의 개념과 그 요건” 참고.

54) 마머는 ‘대다수의 실효적 준수’를 요하면서 관행의 임의성을 ‘효력이 실효성에 조

다. 문제는 관행을 자격화하는 필수적인 두 요건, 즉 ‘임의성’과 ‘준수 의존성’이 과연 ‘규범성(normativity)’과 조화될 수 있는지 여부이다. 논자에 따라서는 규범이란 본질적으로 임의적이거나 조건적 준수의 대상이 될 수 없기에 그런 점에서 보면 관행은 규범이 될 수 없다고 반론할 수도 있다. 마머는 이 점을 들어 “규범성과 임의성의 외견상 역설적인 조합”이라고 표현하기도 한다.⁵⁵⁾ 이 문제는 결국 ‘규범성’을 어떻게 이해할지에 관한 문제와 연결된다. 필자는 규범성을 ‘행위 이유 제공적 규범성’과 ‘책무 산출적 규범성’의 두 측면으로 구분하며, 이론상 ‘규범적’이라는 판단 근거는 전자로도 가능하다. 그런 점에서 보면, 진성 관행이 갖는 임의성이 그것의 규범성을 위협한다고 볼 수는 없다. 두 속성은 긴장관계에 있긴 하지만 양립가능하다.

(3) 대안 정식의 목표와 특징

‘사회적 관행’의 특별한 한 유형으로서 ‘법적 관행’ 개념을 규명한 ‘법적 관행 정식’은 필자의 특별한 문제의식을 구체화하는 방식으로 기존 이론들을 수정·보완하여 고안한 것이다. 이러한 작업의 목표와 지향점은 크게 세 가지다. ① 관행성을 보존하면서도, 변화와 혁신의 가능성을 허용하는 유연한 관행 개념, ② 관행의 본질적인 규범적 특성을 포함하는 관행 개념, ③ 관행성의 극단화나 부정적 변질을 제어하고 규율할 내적 제약원리를 포함하는 관행 개념을 정립하는 것이다. ①은 기존의 정적 관행 이론이 포착하지 못한 관행의 동적 측면을 담는다.⁵⁶⁾ ②③은 게임이론에 기반한 루이스적 관행 모델이

견적임을 수반하는 것으로 설명한다. “만약 그것을 준수할 이유가 기본적으로 그 규칙의 실효성에 의존하지 않는다면 그 규칙은 관행이 될 수 없다.” Marmor, “On Convention,” pp.356-357. 근본적인 도덕규칙이 이에 해당한다고 볼 수 있다.

55) Marmor, “On Convention,” p.349.

56) 필자는 관행 이론의 두 모델을 다음과 같이 유형화한다.

[표 3] 관행 이론의 두 모델

	정적 이론 [정태적 개념관]	동적 이론 [동태적 개념관]
개념관 (conception)	정적 균형	동적 균형
	경직된 개념관	유연한 개념관
연구 주제	준수 의무론	관행의 생성과 소멸 과정

간과한 관행의 규범적 속성을 보완한 것이다. 이 대안 정식을 통하여 필자는 사회적 관행에 관한 ‘일반 이론’의 차원과 ‘법이론’의 차원 양자에서 중요한 개선을 도모했다. 그리고 ‘개념으로서의 관행’과 ‘실례로서의 관행’ 간의 간극⁵⁷⁾을 최소화할 수 있는 공간을 관행 개념론 안에서 확보하고자 하였다. 다만 이 정식의 성격은 법적 관행을 규정하기 위한 논리적인 필요충분조건이라고 볼 수는 없다.

3. 규범적 실천으로서의 관행

‘법학적 관행 이론’의 1단계인 ‘개념분석적 차원’에서 논하고자 하는 또 하나의 주제는 추상적 개념(‘convention’)이 아닌 실재하는 개별 관행들(conventions)의 본질과 특성들에 관한 것이다. 특히 법적 관행의 경우에는 법질서 안에서 체계관련적 지위를 점하면서, 인적·제도적인 차원에서 역동적이고 복잡한 특징이 다채롭게 드러난다.

(1) 개념으로서의 관행 vs. 실례로서의 관행

제도적 법이론의 주창자로 알려진 맥코믹(Neil MacCormick)은 “법의 존재는 제도적 사실의 문제이다.”라는 명제를 주장하면서, 제도(institution)의 철학적 위상을 ‘개념(concept)으로서의 제도’와 ‘실례(an instance)로서의 제도’로 구분한다.⁵⁸⁾ 제도에 대한 맥코믹의 설명은 사회적 관행 이론에서의 그것과 상당한 유사점이 있기에,⁵⁹⁾ 그 구분법을 관행에 적용할 수 있겠다. ‘개념으로서의

(theme)	균형 선택의 문제
---------	-----------

이현경, “동적 관행 이론,” 143면.

57) ‘개념’과 ‘실례’ 혹은 ‘보편자’와 ‘개별자’의 구분은 오랜 철학적 논쟁의 주요 주제 중 하나이다. 법의 본성에 관한 철학적 탐구에서도 이런 구분을 받아들여서 ‘개념으로서의 X’와 ‘실례로서의 X’의 두 차원을 나누어 고찰할 필요가 있다. 이런 접근을 통해 많은 수의 사이비(pseudo)-철학적 문제와 불필요한 논쟁들이 해소될 수 있다고 본다.

58) Neil MacCormick and Ota Weinberger, *An Institutional Theory of Law: New Approach to Legal Positivism*, D. Reidel Publishing Company, 1986.

59) 특히 유럽권에서의 일부 관행주의는 제도적 법이론과 흡사하다. 한 예로, Raimo

관행'과는 달리 그것이 현실에서 구체화된 각각의 '실례로서의 관행'의 실재는 역동적이고 복잡한 특징을 보인다. 우선 '역동성(dynamics)'의 면에서 보면, 관행도 일련의 삶(life)을 이루며 생성과 지속, 변화와 소멸의 과정을 겪는다. 맹아의 단계로 말할 수 있을 관행에서부터 법제화를 거쳐 공식적인 실정법으로 승격된 '협회의 법적 관행'에 이르기까지, 그 스펙트럼은 대단히 폭넓다. 또한 관행은 끊임없이 주변 환경에 적응하고 변모의 과정을 거치면서 내·외부적으로 다양한 양상으로 구현된다. 특히 일종의 지역화된 규범으로서 속성을 갖는 구체적인 개별 관행들은 그것이 발생하는 시·공간, 맥락의 특수성이 반영되어 나타나기도 한다.

구체적인 법적 관행들은 관행을 이루고 있는 내적 구조뿐만 아니라 그것이 실현되고 작동하는 과정에서 여러 차원에서 '복잡성(complexity)'을 갖는다. 특히나 '법적 관행'의 경우에는 그 역동성과 복잡성이 더욱 두드러지며 복합적이다. 이는 다양한 차원에서 논해질 수 있다. 우선 법적 관행은 법체계 안에서 일정한 위상을 점하는데, 이를 통해 자연히 체계 관련적 속성도 갖게 된다. 즉 법적 관행의 경우에는 '내적 체계'와 '외적 체계'⁶⁰⁾의 두 측면에서 정합성을 요구받음으로써 '체계 정당성' 문제와 연결된다. 이 점은 '나쁜 관행'을 판정하는 한 기준으로도 고려될 수 있다. 또 다른 차원에서 보면, '실례로서의 관행'은 다양한 방식과 양상으로 구현되며, 그 과정에서 사회 구조적인 요인과 결합하여 모종의 '실현 메커니즘'이 작동한다. 이 점은 특히 법적 관행과 관련된 분쟁의 본질을 파악하고 적절한 해법을 모색할 때 고려해야 할 중요한 참고사항이 된다.

(2) 관행의 역동성과 제도적 체계화

관행의 복잡성과 역동성이 복합적으로 구현되는 대표적인 예로 '관행의 제

Siltala, "Legal Conventionalism: Law as an Expression of Collective Intentionality," in *Law, Truth, and Reason*, Springer, 2011.

60) 법학방법론의 차원에서 '내적 체계'와 '외적 체계'의 개념 구분은 김영환, 『법철학의 근본문제』, 홍문사, 2012. 이 중 내적 체계에서의 정합성 추구는 원리의 일관성을 주장하는 드워킨의 '통합성으로서의 법(law as integrity)' 명제와 통한다고 볼 수 있다.

도적 체계화’를 들 수 있다. 마머는 관행이 체계화되는 두 방식을 “입법적 체계화(legislative codification)”⁶¹⁾와 “백과사전식 체계화(encyclopediaic codification)”로 구분한다.

[표4] 관행의 제도적 체계화의 두 방식⁶²⁾

	입법적 체계화	백과사전식 체계화
주된 역할	관행의 내용을 결정·수정함.	관행의 내용을 보고·지침함.
성공 시 관행성의 존속 여부	관행성 소멸	관행성 유지
제도적 규칙과의 관계	관행을 대체함.	관행적 규칙은 유지됨.
예		사전, 문법책

관행 규칙들의 “입법적 법제화”는 해당 규칙이 무엇인지 불분명할 때 그 내용을 유권적으로 결정한다. 마머의 설명에 따르면, 만약 기존 관행의 입법적 체계화가 성공하면 그것이 구성하는 실행⁶³⁾은 더 이상 관행적이지 않게 된다. 반면에 “백과사전식 체계화”는 그것의 내용을 장래적으로 결정짓지 않으며, 그 규칙이 무엇인지를 보고할 따름이다. 따라서 백과사전식 체계화의 경우에는 체계화의 성공 여부와 상관없이 그 실행의 관행적 본성은 그대로 유지된다. 또한 “입법적 체계화”는 두 가지 주된 수정(main modification)을 동반한다. 첫째, 입법적 체계화는 변화를 위한 메커니즘을 만든다. 가령 법령의 사후 개정을 위한 절차를 포함한다고 볼 수 있다. 둘째, 입법적 체계화는 규칙 준수를 보장하기 위한 메커니즘도 도입한다. 즉 그것의 준수나 집행의 안정성 확보를 위한 장치로 볼 수 있다. 제도적 실행은 보통 ① 규칙 위반에

61) 본고에서 사용하는 “입법적 체계화”라는 용어는 ‘법제화’를 의미한다. “백과사전식 체계화”와의 차별점을 부각시키기 위하여 ‘체계화’라는 용어를 공통으로 사용한다.

62) 이현경, “동적 관행 이론,” 152면.

63) 마머는 관행을 사회적 실행(social practice)을 구성하는 한 요소로 본다. (본고에서 필자는 ‘practice’를 ‘실천’으로 옮겨왔다. 그러나 마머의 문맥에서는 ‘실행’이란 번역이 더욱 적합하여 여기서는 ‘실행’으로 적는다.) 이는 결국 관행의 한계를 강조하며 사회적 실행을 더욱 중시하는 마머의 법이론적 입장이 전제되어 있다고 볼 수 있다. 반면에 필자는 “관행=규범(=규범적 규칙)*사회적 실천”으로 규정한다.

대한 제재를 정하는 규칙을 가지며, ② 규칙에 대한 부준수(不遵守)를 감시하고 그 위반에 대한 제재 방법, 그리고 ③ 누가 그런 사안들을 결정하게 되는지 등을 결정하는 전체 메커니즘을 갖는다.⁶⁴⁾

그런데 필자가 생각하기에 ‘입법적 체계화’는 기존 관행의 내용을 있는 그대로 반영하는 ‘순방향(+) 체계화’와 관행 규칙과 반대되는 내용을 규정하는 ‘역방향(-) 체계화’라는 두 방식으로 구체화될 수 있다.⁶⁵⁾ 가령 일부 민사관습 법규범들이 민법전에 흡수되어 성문화된 것은 ‘입법적 체계화’의 한 예로 볼 수 있다. 반면에 ‘역방향의 입법적 체계화’를 보여주는 최근의 예로는, 소위 “전판예우금지법”, “부정청탁금지법”, 그리고 “연명의료결정법” 등을 들 수 있다. 또한 ‘상가권리금 수수 관행’을 둘러싼 문제가 2015년 5월 ‘상가건물 임대차보호법’의 개정을 통해 ‘관행 계약’으로 법제화된 사례 역시 법적 관행의 역동성이 구현되는 과정과 법적 관행을 둘러싼 관련 사람들의 복잡한 구조 및 상호 관계의 다양한 양상을 잘 보여준다.

(3) “관행 ≍ 규범 * 사회적 실천”

관행은 특별한 종류의 규범이면서 동시에 사람들의 사회적 상호작용을 존재 기반으로 삼는다. 그런 점에서 관행을 ‘실천된 규범(practiced norm)’ 혹은 ‘규범적 실천’으로 부를 수 있다. 다시 말해 관행은 ‘사회적 실천’과 ‘규범적 규칙(normative rule)’, 즉 ‘규범’이 결합된 ‘규범적 실천’으로도 재규정할 수 있다.⁶⁶⁾ 두 요소의 의미는 대조군을 통해 분명히 이해될 수 있다. 우선 규범적

64) Marmor, *Social Conventions*, pp.50-52.

65) 하지만 이러한 두 유형 역시 일종의 이념형적 분류로서, 실제 사례에서는 둘 중 택일하여 구분하기는 어렵다. 가령 기존에 관행 상 인정되었던 권리금 수수 관행이 임대인의 방해 금지 의무라는 특이한 형태로 “상가건물 임대차보호법”에 규정된 사례도 두 유형 간의 변형태가 가능함을 보여준다.

66) 일부 사회적 규칙이론이나 실천 이론(practice theory)들이 전제하는 바와 같이, 규칙 안에는 실천의 요소가 포함되어 있기도 하다. “사회적 실천이 규칙을 낳는다. 왜냐하면 그런 규칙들은 사회적 실천에 다름 아니기 때문이다.” Scott J. Shapiro, *Legality*, Harvard University Press, 2011, p.95. 대표적으로 하트의 규칙 이론은 ‘규칙에 대한 실천 이론’으로 명명되기도 한다. Shapiro, *Legality*, pp.95-96. 샤피로는 하트의 규칙 이론을 “실천 이론(The Practice Theory)”이란 표제 하에 소개하면서, “사회적 규칙은 집단 구성원들에 의해 받아들여지고 실행되는 덕분에 존재하게

이지 않은 규칙, 즉 자연 법칙이나 기술적 노하우 등이 비규범적 규칙의 예다. 반면에 관행은 규범적 규칙이다.⁶⁷⁾ 또한 상호작용이나 실천을 전제하지 않는 초월적인 선험적 규범이나 책 속의 규범도 있다. 하지만 관행은 ‘실천됨 (being practiced)’을 존재론적 기반으로 하는 사회적 규칙인데, 이 점이 도덕 규칙이나 법규칙과의 본질적인 차이 중 하나다. 즉 관행을 ‘규범’과 ‘실천’이라는 두 개의 기본적인 단위로 분석함으로써, 관행의 특수성을 더 잘 파악하고 분별할 수 있다. 요컨대 “관행 ≡ 규범 * 사회적 실천”으로 정식화할 수 있다. 관행에 대한 이러한 설명은 철학적 차원에서 ‘개념으로서의 관행’을 넘어 그것이 실제 구현된 개별적인 사례들의 다양한 양상과 실태를 관행 개념론 안에서 다룰 수 있는 이론적 가능성을 제공한다. 이러한 설명을 기초로 이하 III.에서는 관행 규범성의 특징과 정당화근거를 중심으로 논의를 심화시켜보자.

III. 〈2단계〉: 관행의 효력과 정당화 근거⁶⁸⁾

‘법적 관행 정식’에 대한 설명을 통해 정식의 요건을 충족한 진성 관행은 그 자체로 규범적 속성을 획득함을 확인하였다. 즉 관행은 특별한 종류의 규범이다. 이하에서는 규범으로서 관행이 갖는 특수성은 무엇인지, 그리고 관행 규범성의 원천과 효력 근거에 대해 본격적으로 논하고자 한다. ‘관행의 규범

된다.”고 설명한다. 마머도 승인 규칙의 본성에 관한 하트의 원래 정식을 “규칙에 대한 실천 이론”이라고 표현한다. Marmor, *Social Conventions*, p.156.

67) 규칙의 유형은 ‘사실 기술적 규칙(descriptive rule)’, ‘기술적 규칙(technical rule)’ 그리고 ‘규범적 규칙(normative rule)’으로 구분할 수 있다. 이 중 ‘규범적 규칙’은 인간의 행위를 향도, 통제, 변경하려는 규범적 압력을 발하는 규칙이다. 예컨대 도덕, 법, 관습 등이 대표적인 예가 된다. 심현섭, “규범의 일반이론에 관한 연구,” 『분석과 비판의 법철학』, 법문사, 2001, 60-62면; Ota Weinberger, “The Role of Rules,” *Ratio Juris*, Vol. 1, No. 3, 1988, pp.224-240.

68) 이 장에서의 서술 중 상당 부분은 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰,” 『법학논총』 제34집 제3호, 한양대학교 법학연구소, 2017에서도 활용된 바 있음.

성', 더 구체적으로는 "규범으로서 관행"이라는 논제를 해명하기 위해서는 명제를 구성하는 세 요소로 분할하는 것이 도움이 될 것이다. ① '관행', ② '규범(성)', 그리고 관행이 갖는 규범성의 특별함을 담는 ③ '으로서'라는 결합소(結合素). 앞선 제Ⅱ장에서는 ① '관행'에 집중하였다면, 이하의 제Ⅲ장에서는 나머지 두 요소를 중심으로 논한다.

1. 회의론을 넘어

(1) 회의론의 두 유형: '사회학적 환원론'과 '철학적 관행주의'

필자는 진성 관행은 그 자체로 규범성을 내포한다는 입장을 취한다. 이런 관점에서 보면, 필자가 극복하고자 하는 첫 번째 이론적 대결자는 관행의 규범성을 부정하는 회의론자들이다. 크게는 '사회학적 환원론'과 '철학적 관행주의'로 유형화할 수 있다. '사회학적 환원론'은 관행이란 규범력을 수반하지 않은 순전한 사회적 사실로서, 그 본질을 그저 오랜 기간 반복·누적되어온 행위 정규성으로 파악한다. 이는 흄의 법칙과 엄격한 존재·당위 이원론에 철학적 기초로 둔다고 볼 수 있다. 그런데 법학에서도 이런 견해는 존재하는데, 특히 노동 관련 판례나 관습법 관련 판례들에서 종종 확인할 수 있다.⁶⁹⁾ 또한 법사회학에서도 관행의 규범성을 부정하는 듯한 견해가 있다.⁷⁰⁾ 대상으로서 관행이 갖는 속성 자체에 대한 이러한 회의적 시각과는 다르지만, 이와 유사

69) "판례에 의하면 노동관행은 규범의식에 의하여 지지되고 있는 사실을 의미하는 것이므로 노동관행 자체가 규범적 효력을 가지는 것이라고는 볼 수 없다." 김형배, 『노동법』, 박영사, 2014, 101면. 관습법의 성립요건을 '사실로서의 관행 또는 관습'과 '법적 확신'이라는 이원적 구성으로 설명하는 전통적인 학설 역시 관행의 규범력에 대한 회의적 입장으로 해석할 수 있다.

70) 예컨대 김도현 교수는 베버의 견해를 인용하면서, "규칙으로서의 법은 단순한 관행(usage)이나 관습(custom)이 아니다. 관행은 현실적으로 동일한 유형의 행위가 일어난다는 의미이다. 예컨대 "그는 규칙적으로 6시에 일어난다"고 할 때의 '규칙적'은 사실 상태의 단순한 누적이지 규범적 성격을 지닌 규칙이 아니다. 관습은 관행이 오랜 기간 계속된 것이다. 관행과 관습의 차이는 존속 기간의 상대성밖에 없다."고 설명한다. 김도현, 『법이란 무엇인가』, 동국대학교출판부, 2007, 125면. 인용문에서의 용어 사용이 본고에서의 것과는 다르지만 실질적 의미에서는 큰 차이가 없다.

한 태도로 관행을 바라보는 또 다른 극단은 논리철학에서의 관행주의와 일면 연결된다. ‘관행주의(conventionalism)’⁷¹⁾는 관행을 어떤 현상을 설명하기 위한 도구적 개념으로 다룬다. 특히 언어분석철학에서의 ‘철학적 관행주의’는 관행 그 자체는 일종의 공허한 개념으로서 그 실체나 배후에 대해서는 묻지 않겠다는 태도를 말한다. 한편으로는 켈젠의 ‘근본규범’을 떠올리게도 하는 이런 입장은, 사회적 현상이자 실재(reality)로서 존재하는 관행의 실체를 제대로 설명하지 못할 뿐 아니라 그것이 발휘하는 현실 규범력을 무시하는 우를 범한다. 필자는 두 입장 모두 합당하지 않다고 본다. 이러한 견해들은 특히 법적 분쟁으로까지 비화되는 ‘법적 관행’의 경우에 이론적이나 실천적으로 기여할 수 있는 바가 매우 적을 것이다. 요컨대 관행의 규범성과 관련하여 ‘사회학적 환원론’이나 ‘철학적 관행주의’의 두 회의론적 입장은 특히 ‘법적 관행’을 논하는데 있어서는 설명력의 면에서나 실천적 함의의 면에서도 부적절함이 있다. 관행은 모종의 규범적 실천으로서, 정도와 방식의 차이는 있을지언정 그것의 품질을 평가할 수 있는 가치 판단의 대상이다. 이런 관점을 전제할 때 우리는 관행의 효력과 평가 문제, 그리고 그에 대한 준수 의무 역시 충실히 논할 수 있게 된다.

(2) 규범이 갖는 징표

일반적으로 ‘규범’이란 집단에 의해 수용되거나 기대되는 사회적 행위의 기준이나 패턴을 말한다.⁷²⁾ 즉 규범은 일정한 행위를 해야 할 또는 하지 않아야 할 의무를 지우거나, 어떤 행위를 하도록 허용하면서 인간의 행위를 ‘당위적으로’ 규정하는 규칙들이다. 규범력이란 시민들이 어떤 행위를 하는 이유에 영향을 미칠 수 있는 능력⁷³⁾이다. 그렇게 본다면 관행은 규범이며, 묵시적인 사회적 규칙이다. 규범적 규칙, 즉 규범으로서 관행이 갖는 징표는 크게 두

71) ‘관행주의’란 어떤 현상이 관행으로부터 발생하거나 관행에 의해 결정된다는 교의를 뜻한다. 즉 어떤 종류의 근본 원리들이 사회 안에서 명시적 혹은 묵시적 합의들에 근거한다는 철학적 태도를 말한다. Michael Rescorla, “Convention,” *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2011, p.4.

72) “Norm,” in *Oxford English Dictionary Online*, Oxford University Press, 2010.

73) Jules L. Coleman, “Authority and Reasons,” *The Autonomy of Law*, Oxford, 1996, p.297.

가지다. 그 규칙에 대한 위반이 가능하다. 소극적 측면에서 보면, 위반 행위에 대한 행위자 스스로의 심리적 반응이나 외부의 처우를 통해 그 규범성을 확인할 수 있다. 적극적 측면으로는 규칙이 갖는 행위 향도적 기능, 평가 기준을 제공하고 나아가 준수 의무를 창출할 수 있다는 점을 특징으로 한다.

2. 규범적 관행의 특수성: 규범적 위계

(1) 관행의 규범적 위계: '성립 · 존재 조건' vs. '강화 조건'

관행 정식을 충족한 진성 관행의 경우에도 규범적 위계가 있다. 즉 '그저 관행인 것(mere convention)'과 '강력한 관행'을 구분할 수 있다. 전술한 관행 정식은 관행이 성립하기 위한 최소한의 자격 요건이자 존재조건이다. 그런데 경우에 따라서는 일정 요소들이 추가 · 결합됨으로써 애초의 관행이 규범적으로나 사실적으로 더욱 견고하고 강력한 관행이 될 수 있다.⁷⁴⁾ 관행의 존재 조건('성립 · 존재 조건')과 그것의 사실성이나 규범성을 강화시키는 조건('강화 조건')은 구분될 수 있으며 그러해야 한다는 것이 필자의 주장이다. 필자는 이를 관행의 '성립 · 존재조건'과 구분되는 '강화 조건'이라 부르며, 그 요건들은 다음과 같다. ① 공통 지식과 공식적 표명, ② 시간적 지속과 반복, ③ 제도적 지지, ④ 도덕적 이유들. 각 요건의 의미를 살펴보자.

첫째, 관행은 공통 지식과 표명을 통해 강화될 수 있다. 공통 지식(common knowledge) 조건은 루이스 관행 개념을 이루는 필수요건 중 하나지만, 여러 측면에서 비판을 받기도 했다. 필자는 공통 지식 조건은 관행이 되기 위한 '성립 조건'보다는 '강화 조건'으로 이해될 수 있다고 주장한다. 또한 이 조건은 관행 당사자들의 인식 상태나 지성적 측면에 국한되지 않는다. 보다 넓게 이해된 공통 지식 요건은 관행이 공식적으로 표명되거나 공포되는 것까지도

74) 이 이론의 발상은 존 쉘의 통찰을 참고했다. 쉘은 복잡하고 '강력한 사회적 실재를 건설하는' 방법을 논하면서 "이처럼 단순한 메커니즘을 사용해서, 즉 그 메커니즘의 연동 작용 및 메커니즘을 여러 번 반복하며 하나를 다른 하나에 덧씌워서, 놀랍도록 풍부한 사회적 구조를 만드는 데 사용할 수 있는 것이다." 존 쉘(심철호 옮김), 『정신 · 언어 · 사회』, 해냄, 2000, 174면. 이 주제와 관련된 상세한 설명은 John R. Searle, *The Construction of Social Reality*, New York, 1995 참고.

포함할 수 있다. 둘째, 관행은 시간적 지속과 횡수의 누적·반복을 통한 강화된다. 다시 말해 관행이 성립되고 자격을 인정받기 위해서 오랜 기간에 걸쳐 반복적으로 행해져야 한다는 사실적 조건이 꼭 필요한 것은 아니다. 시간적 지속과 반복성은 관행 성립의 충분조건일 수 있지만 필요조건은 아니다. 만약 어떤 관행이 이런 조건을 충족한다면 더욱 견고하게 외형을 갖추고 공식화됨으로써 점차로 강력한 (제도적) 관행이 될 수 있다. 예컨대 오랜 기간 반복적인 습관화의 과정을 거쳐 공동체 내에서 널리 승인된 “관습적 관행”은 관습의 한 형태라고도 볼 수 있다.⁷⁵⁾ 셋째, 관행은 공식적인 제도적 지지를 통해 강화된다. 사회적 관행은 기본적으로 당사자들 간의 협력적 상호작용을 통해 자율적으로 형성·유지되는 규범으로, 공식적인 제재 메커니즘은 갖고 있지 않다. 그러나 경우에 따라서는 관행에도 제도적 권위가 부착되거나 공식적인 제재가 수반될 수 있다. 그 경우 관행은 더욱 강력한 실천력과 실효성을 획득하게 된다. 넷째, 도덕적 이유의 결함을 통해 관행은 강화된다. 이는 두 가지 방식으로 구체화 될 수 있다. 우선, 관행이 담고 있는 내용 자체가 도덕적으로 바람직하거나 사회적으로 권장되는 ‘도덕적 관행’인 경우 그 위상은 더욱 강화될 것이다. 왜냐하면 도덕적 관행은 인식적 차원에서 사람들에게 긍정적 영향을 미치고, 그 결과 그것에 따를 적극적 이유를 구성할 수 있기 때문이다. 또한 관행의 내용과는 무관하게 그것이 구성하는 사회적 실행에 따를 외부의 강력한 도덕적 이유가 존재할 경우⁷⁶⁾에도 이는 강력한 관행이 되어, 준수 책무가 발생할 수 있다.

75) ‘관습적 관행’이라는 표현은 머피의 용어를 차용한 것이다. James Bernard Murphy, “Habit and Convention at the foundation of custom,” Perreau-Saussine, Amanda, · Murphy, James Bernard (Ed.), in *The Nature of Customary Law*, Cambridge University Press, 2007, p. 66. 그러나 본고의 대안 이론은 “관습≒관행*습관화” 관계식을 주장하기에, 이에 따르면 ‘관습적 관행(customary convention)’이란 표현은 자체 모순을 내포한다고 볼 수 있다. 그리고 ‘관습(custom)’은 관행이 강화 조건을 충족한 강력한 관행의 한 유형으로 설명할 수도 있다. 자세한 사항은 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 223-230면 참고.

76) 가령 어떤 가족 내부에 관행 A가 있다면, 가족 구성원으로서 딸은 A의 내용과는 무관하게 그 관행을 따라할 도덕적인 이유가 있다고 볼 수도 있다. 왜냐하면 ‘가족’이라는 특별한 혈연 공동체를 화목하게 유지해야 한다는 도덕적 책무가 관행 A를 따를 도덕적인 이유의 일부가 될 수 있기 때문이다.

(2) 관행 규범력의 정도: ‘이유 제공적 규범성’과 ‘책무 산출적 규범성’

관행의 규범적 위계의 또 다른 국면으로 관행이 갖는 규범력은 정도차가 있다. 규범성은 일인칭 참여자의 관점에서 실천적 추론의 차원에서 관행이 발휘하는 실천적 힘에 주목하여 해명될 수 있다. 이런 전제 하에, 규범성을 ‘이유 제공적 규범성’과 ‘책무 산출적 규범성’으로 구분할 수 있다. 첫째, ‘이유 제공적 규범성’과 ‘책무 산출적 규범성’은 다른 종류의 것이라기보다 강도에 있어서 차등적이다. 즉 책무 산출적 규범력은 이유 제공적 규범력에 비해 더 강력하며, 강제규범의 위상을 획득하기도 한다. 둘째, 진성 관행은 ‘이유 제공적 규범성’은 그 자체로 확보되지만 ‘책무 산출적 규범성’은 보장받지 못한다. 관행이 존재한다면 우리는 그것에 따라야 할 행위 이유를 갖게 되지만, 복종할 책무가 있는지는 부분적으로 결정될 따름이다. 관행을 둘러싼 모종의 규범적 토양, 외부의 사회·도덕적 고려사항이나 행위자의 역할 규범, 기타 규범적 원리 등의 추가 요소들이 결합됨에 따라 관행적 책무의 존부가 결정된다. 결국 관행의 책무 산출적 규범성은 가치관계적 함수로 확장될 수 있다. 법적 관행의 경우에는 구조적 요인도 중요한 변인이 된다.

이 외에도 규범적 관행의 ‘제도적 위계’도 논할 수 있다. 즉 순수하게 비공식적인 자율적 규범질서로서의 묵시적 관행에서부터 그것이 법제화를 통해 공식적인 실정법규칙으로 승격된 (최협의의) ‘법적 관행’에 이르기까지 그 스펙트럼은 대단히 넓다. 이 점은 앞서 본고 제II-3.(관행의 역동성과 법제화)에서의 논의와도 연결된다고 볼 수 있다.

2. 관행 규범성의 원천: 다층적 정당화 논변

규범성에 관한 합당한 이론이라면 ‘설명’과 ‘정당화’라는 두 과제에 충실히 답할 수 있어야 한다.⁷⁷⁾ 보통 전자는 ‘어떻게’에 관한 질문으로, 후자는 ‘왜’에 관한 질문으로 이해된다. 이하에서는 관행 규범성의 원천이자 정당화 근거를 논구한다. 기초 작업으로서 우선 관행의 본질적 규범성에 대한 가장 강력한

77) 마머는 법의 규범성에 관한 철학적 이해관심은 ① 설명적 과제와 ② 정당화 과제의 두 측면으로 구분된다고 말한다. 자세한 설명은 Andrei Marmor and Alexander Sarch, “The Nature of Law,” in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2001.

옹호자인 길버트(Margaret Gilbert)의 이론을 비판적으로 검토하고, 이를 기초로 대안 이론 정립의 필요성과 요건을 제시한다. 관행 규범성의 원천에 대한 가능한 정당화 논변들을 일부 고찰 한 후, 필자는 최종적으로 ‘다층적 정당화 논변’을 주장한다.

(1) 길버트의 합동 수용 설명법 검토: ‘합동 결의 논변’

길버트는 자신의 ‘합동 수용 논법(joint acceptance account)’을 통해 관행의 ‘당위’란 존재하며 관행의 규범성의 본령은 합동 수용을 구성하는 ‘합동 결의(joint commitment)의 규범성’에 있다고 주장한다. 합동 결의를 창설하는 이들은 합동 결의의 공동창안자(co-creators)이다. 그들은 서로에게 어떤 제약을 함께 부과하며, 각 당사자들의 행위 준수를 합동적으로 소유하게 된다.⁷⁸⁾ 왜냐하면 각자는 합동 결의를 통해 그것을 준수하는데 연루되기 때문이다. 그녀의 설명에 따르면, 각 당사자는 다른 모든 당사자들에게 합동 결의에 대한 그의 준수를 빚지고 있다. “직관적으로 볼 때, 당신이 나에게 어떤 행위를 빚지고 있음(your owing me an action)은 당신이 그 행위를 수행할 충분한 이유가 된다.”⁷⁹⁾ 길버트는 이 점이 무조건적인 절대 복종을 의미하는 것은 아니지만, 다른 모든 조건이 같다면 그것을 준수해야 하고 “일반적으로 의지 결의의 ‘당위’가 있듯이 빚지는 것의 ‘당위’가 있다.”⁸⁰⁾고 한다.⁸¹⁾

길버트의 설명에 따르면, ‘누군가에게 어떤 행위를 빚지고 있음’ 논변은 세 가지 역할을 한다. 이 논변은 ① 그 행위를 수행할 충분한 이유를 제공하며, 따라서 준수 의무가 도출된다. ② 이는 다른 사람에게 그 행위를 요구하고 만약 그것이 수행되지 않을 경우 힐책할 자격을 부여한다. 그리고 ③ 그런

78) Margaret Gilbert, “Social Convention Revisited,” *Topoi*, Vol. 27, p.13. 이는 특별한 종류의 소유권(ownership)이다. 길버트는 이것을 인간의 사회적 존재성에 근본적인 것으로 여긴다. Gilbert, 위의 글, p.13, 각주 65.

79) Gilbert, “Social Convention Revisited,” p.14.

80) Gilbert, 위의 글, p.14.

81) 길버트는 ‘합동 결의’의 면에서 관행을 다음과 같이 설명한다. “인구집단 P는 오직 다음의 경우에만 유형 S의 상황에서 행위R에의 정규성에 대한 준수 관행을 갖는다. 즉 P의 구성원들은 ‘R은 준수될 것이다’는 엄명에 대해 스스로 하나의 총체로서 공동으로 결의할 때에만 그러하다.” Gilbert, 위의 글, p.12.

행위의 요청이나 힐책의 정당화 근거를 제공한다.⁸²⁾ 특히 그녀는 ‘반칙 기준(The Offense Criterion)’을 제시하면서, 이를 “일방 당사자의 부준수(不遵守)는 타방에 대한 반칙이다.”는 주장에 대한 구체화로 설명한다.⁸³⁾ 합동 결의에의 불복종자는 필요적 의미에서 다른 당사자들에 대해 반칙을 한 것이다. 다시 말해 그는 합동 결의의 공동 창안자로서, 그가 그들에게 빚진 것을 제공하지 않은 것이다. 이런 논증은 본질적으로 ‘결의의 규범성’과 ‘결의의 합동성’에 호소하는 것이다. 또한 길버트에 따르면 관행의 존재와 규범력은 전적으로 최초의 합동 결의에 의해 결정되며, 다른 사람들이 관행을 준수할 것이라는 기대에 의존하지 않는다. “관행은 누군가가 그것을 행하기 이전에 이미 존재할 뿐만 아니라 일반적 준수가 결여된 상황에서도 존재한다.” 이 점에서도 그녀의 설명은 준수 의존성을 관행 성립의 필수조건으로 요하는 루이스와 근본적으로 다르다.

길버트는 “관행이라는 우리의 일상 개념은 공동으로 수용된 행위 원리의, 특정한 상황에서 우리가 어떻게 행동하는지와 관련된 집단 엄명이다.” 라고 정의한다.⁸⁴⁾ 요컨대 길버트는 강한 집단주의적 개념관을 수립하고 이를 통해 관행 자체에 내재된 본질적 규범성을 강조한다. 이 논변에 따르면, 누군가 관행을 채택한다는 것은 곧 집단 엄명을 증진시킬 공동 목표를 수용하고 의욕을 표명하는 것이며, 이는 다중 주체(plural subject)⁸⁵⁾를 구성하여 관행 당사자들이 모두 다함께 그것에 복종할 의무가 자연스레 도출된다. 또한 관행에의 불복종은 서로에게 빚지고 있는 당위를 어김으로써 일종의 반칙을 행하는 것

82) Gilbert, 위의 글, p.14.

83) “일반화하기: 만약 일방이 관행을 준수하지 않는다면, 이는 그 자체로 타방에 대해 반칙을 범하는 것(offend against)이다. 따라서 그들은 부준수(不遵守)에 대해 그위반자를 힐책할 수 있다. 또한 그들은 그들 집단이 그 관행을 갖는다는 사실을 힐책에 대한 완벽한 정당화 근거로 인용할 수 있다. 그렇다면 관행은 분명 무시할 수 없는 힘(force)이 되는데, 왜냐하면 적어도 그들은 만약 누군가 [관행을] 부준수할 경우 그를 다른 당사자들에 의해 힐책받는 처지에 놓이게 하기 때문이다.” Gilbert, 위의 글, p.7.

84) Margaret Gilbert, *On Social Facts*, Routledge, 1989, p.377.

85) ‘다중 주체’란 공동 목표를 증진하고 신념을 공유하며, 어떤 행위 원리 하에 활동한다고 스스로 여기는 행위자들의 집합을 말한다. 자세한 사항은 특히 Gilbert, *On Social Facts*, chap. 4. 참고.

으로 볼 수 있다.

생각건대, 관행의 규범성의 원천을 ‘집단 엄명에 대한 집단적인 합동 결의’에 호소하는 길버트의 설명은 ‘법적 관행 모델’로 차용하기에는 무리가 있다. 첫째, 법적 관행의 배경이 되는 공동체는 길버트가 상정하는 것만큼 균질적이고 강고한 신념 공동체로 보기 어렵다. 둘째, 길버트의 설명에 따르면 관행에의 책무는 전적으로 최초의 합동 결의를 통해 형성된다. 하지만 많은 경우 관행에의 참여자들은 관행의 최초 형성에 직접 관여하지 않았는데, 어떻게 ‘합동 결의의 당위’가 그에게 곧바로 이전되는지에 대한 추가 논변이 요청된다. 셋째, 책무 부담의 주체나 방향은 엄격하게 합동 결의의 상대방에 한정된다. 그리고 그들 사이의 관계는 ‘합동 결의에의 다중 주체’이자 ‘관행의 공동 창안자’로서의 속성만으로 규정된다. 하지만 법적 분쟁으로까지 비화되는 많은 법적 관행 사안의 경우, 관련 당사자들은 복합적인 이해관계로 얽혀있거나 구조화된 시스템에 연루되어 있고, 또 여러 차원에서 비대칭적인 위상을 보인다. 따라서 정당화 논변이 그런 요소들을 무시한다면 불완전한 이론이 될 수밖에 없다. 그런데 길버트의 설명 안에는 그러한 점에 대한 고려는 찾기 어렵다. 넷째, 법적 관행의 경우에는 그것이 속해있는 상위 법질서와의 체계 적합성도 중요한데, 길버트의 사회적 관행 이론 안에서는 이 점이 설명되지 못한다. 결론적으로, 그녀의 이론은 관행이 갖는 본질적인 내재적 규범성에 대한 가장 적극적인 논변을 제공하긴 하지만 이를 ‘유일한’ 논변으로 삼기에는 무리가 있다. 길버트는 자신의 이론이야말로 “우리의 일상적 관행 개념”에 대한 성공적인 설명을 제공한다고 주장한다.⁸⁶⁾ 그러나 법적 관행 모델의 논의 대상은 일상 관행을 넘어서나. 법학적 관행 이론에 요구되는 물음들에 답하기 위해서는 ‘법적 관행’의 특수성을 반영하고 위의 결함들을 보완한 대안 이론을 마련할 필요가 있다.

86) Margaret Gilbert, *Joint Commitment: How We Make the Social World*, Oxford University Press, 2014, pp.212-214; Gilbert, “Social Convention Revisited,” pp.5-6.

(2) '다층적 책무'와 '다층적 정당화 논변'⁸⁷⁾

결론부터 말하자면, 필자가 '책무 산출적 규범성'으로 부른 법적 관행에의 준수 의무는 '다층적 책무성'을 가지며, 따라서 그 규범성의 원천을 궁구하는 정당화 논변 역시 복합적이다. 즉 '다층적 정당화 논변'이 그 답이다. 이런 주장을 논증하기 위해 '다층적 책무'의 의미부터 살펴보자.

'다층적 책무(multi-layered obligation)'의 '다층성'은 책무의 부담 주체와 대상, 그리고 책무의 정도라는 면에서 이해될 수 있다. 전술한 바와 같이, 현실에서 관행에의 참여자는 언제나 동등한 권한과 위상을 갖고 있지는 않으며 그 내부에도 넓은 스펙트럼이 존재할 수 있다.⁸⁸⁾ 구체적으로 말하면, 우선 관행의 창안자(길버트의 표현을 빌리자면)를 포함하여 실례로서의 해당 관행에의 직접적인 이해 당사자로서 '일선의 참여자(first-line participants)', 그리고 직접 당사자는 아니지만 관행이 복무하는 목표나 가치를 실현하는데 일정 부담을 안고 관여하거나 실제 그 효과를 향유하기도 하는 '이선의 참여자(second-line participants)'를 구분할 수 있다.⁸⁹⁾ 그리고 이렇게 서열화 된 각 참여자들이 부담하는 책무의 정도나 성격도 여건에 따라 상이할 수 있다.

관행에의 준수 의무가 본질적으로 다층적 책무의 속성을 갖기에, 규범성의 원천도 복합적이다. 또한 실재하는 사회적 관행들은 특정한 맥락과 목적을 전제로 각기 고유한 이야기를 갖고 형성된 구체화된 규범의 성격이 강하다. 따라서 관행의 유형과 관행성의 정도, 관련된 사회적 실천의 성격에 따라 여러 후보 논변들을 적절히 참조할 수 있다. 결론적으로 관행의 규범성에 대한

87) 필자는 이러한 다층적 정당화 논변을 관통하고 그 토대를 제공하는 근본적인 개념으로 '상호의존적 신뢰(mutual reliance)'를 주장하고자 한다. 이에 관해서는 후속 연구를 통해 별도의 논문으로 구명할 것이다.

88) 이는 본고 III-3.에서 논한 관행의 복잡성의 한 측면으로 볼 수 있다. 현실에 실재하는 관행 당사자들은 도덕적 혹은 정치권력적 지위나 권한에 있어 동등하리라는 보장이 없다. 이러한 비대칭성은 계약론적 정당화 논변의 한계가 되기도 한다. 관행 관련 법적 분쟁에 대한 적실한 해결방안을 모색하기 위해서는 무엇보다 이 점에 대한 체계적인 분석과 이론화가 필요하다.

89) '일선 참여자'와 '이선 참여자'의 구분은 맥코믹의 제도 관련 행위자론으로부터 아이디어를 얻었다. 이에 관해서는 이현경, "제도적 사실로부터 제도적 규범질서로," 제IV장 참고.

정당화 근거 역시 일원화된 논변에 호소할 수는 없으며, 목적과 맥락에 따라 여러 후보들이 ‘다층적인 정당화 논변’을 구성하게 된다. 이러한 전제 하에 필자는 관행의 규범성의 원천이나 관행적 책무의 근거로 ‘기능주의 논변’,⁹⁰⁾ ‘계약주의 논변’,⁹¹⁾ 그리고 흄의 ‘공감 논변’⁹²⁾ 등이 고려될 수 있다고 본다.

결론부터 말하면, 관행 정식을 충족한 진성 관행은 발생적 차원에서 이미 모종의 민주적 정당성을 획득한다. 이러한 ‘발생학적 정당화 논변’은 관행은 조정 문제를 해결해 주기 때문에 그것에 따를 책무가 발생한다는, 즉 조정력

90) ‘기능주의 논변’은 조정력에 기초한 정당화 근거로, 특히 조정 관행의 경우 가장 먼저 떠올릴 수 있는 논변이다. 이에 따르면 조정 관행의 규범력과 권위는 일차적으로 조정 문제 해결이라는 기능에 의존한다. 참고로 베손은 “조정에 기초한 법복종 의무”를 두 유형으로 분류한다. (i) The Mixed pedigree of coordination-based duties to obey the law (ii) Coordination-based obligations qua obligations of fair play. Samantha Besson, *The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the Law*, Hart Publishing, 2005, pp.459-489.

91) ‘계약주의 논변’은 관행의 본질을 일련의 ‘조정된 기대’의 집합으로 파악하고 ‘목적적 합의’로 설명한다. 이렇게 보면 관행 이론은 계약주의의 한 변형으로 이해될 수도 있다. 이런 접근은 주로 게임 이론을 계승한 경제학 분야에서 이뤄지는 해석이지만 ‘합의’라는 개념을 특별히 강하게 독해하지 않는 이상 많은 관행 이론가들에게 받아들여지는 설명이기도 하다. Robert Sugden, “Conventions,” in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Peter Newman (Ed.), 1998, p.456. 그러나 관행을 ‘목적적 합의’로 정의하고 사회계약론의 정당화 논변에 의존하게 되면 사회계약론 자체가 갖고 있는 문제점을 그대로 흡수하게 된다는 한계가 있다. 계약주의 논변의 근본적 한계에 관해서는, 이현경, “규범으로서의 관행,” 287면; 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 175-179면.

92) “정의(正義) 관행 수립을 위한 최초의 동기는 자기 이익관심(self-interest)에 있지만, 관행에 일치되게 행동하는 것은 공적 이익(public interest)에 대한 공감과 그에 따른 도덕적 찬동에 의거한다.” Hume, *A Treatise of Human Nature*, pp.499-500; Sugden, “Conventions,” p.457. 흄에 따르면 타인에 대한 공감은 인간 본성의 한 부분이며 이는 찬동(approval)과 불찬동의 심리적 기초가 된다. 우리는 모든 사람들의 행복을 증진시키는 행위에 도덕적 승인을 부여하며, 이것이 결국 공공 이익에 기여한다. 따라서 만약 관행이 일반적으로 널리 준수되면 관행에 일치되는 개별 행위가 모든 이들에게 혜택을 줄 것이고, 그 결과 규범이 된다. 요컨대 관행 형성의 최초 동기는 타산적인 사익 추구에서 비롯되지만 그것이 만연하고 관행 규범으로 확립되는 도덕적 찬동은 전체로서의 관행 그 자체에 겨냥되어 있다. 그리고 이는 각자의 관행 준수라는 일반적 실천이 모든 이들에게 혜택이 되기 때문에 가능하다.

에 기반한 ‘기능주의 논변’과 함께 관행의 규범성을 해명하는 1차적인 문턱점 역할을 한다. 하지만 그것을 유일한 정당화 논변으로 하기에는 각기 한계가 있다.⁹³⁾ 이를 보완하기 위해 결합되는 추가 논변으로 ‘계약주의 논변’과 흄의 ‘공감 논변’이 함께 검토될 수 있다. 다만 ‘공정성’에 대한 고려는 모든 후보 논변들을 해석하고 조율하는데 요청되는 필수 원리로 기능한다. 즉 ‘공정성 논변’은 관행의 규범성의 존부를 둘러싼 대립된 양측 모두에게 중요한 역할을 한다. 특히 법적 관행의 경우에는 공정성 논변이 더 큰 의미를 갖는다.

3. ‘관행 존중의 원칙’

관행은 참여자들의 자율적인 규범질서로서 우선 존중되어야 한다. 이를 ‘관행 존중의 원칙’이라 불리보자. 구체적으로 말하면, ‘관행 존중의 원칙’이란 관행 정식을 충족한 진성 관행은 그 자체로 존중받을 자격이 있음을 뜻한다. 그렇다면 이어지는 물음은 ‘존중’의 주체와 대상, 내용과 방식, 그리고 존중의 정도 등으로 구체화될 수 있다. 각 항목을 나누어서 살펴보자.

93) ‘순수한 버전의 조정력에 기초한 기능주의 논변’은 몇 가지 결함을 내포한다. 첫째, 그것이 전제하는 인간상에 의문이 든다. 인간은 결코 자신의 타산적인 사의 실현에만 급급한 ‘이기적 합리주의자’로 단정할 수 없다(‘인간상’). 둘째, 만약 그 관행이 (어떠한 연유에서건) 현실적으로 조정 문제 해결에 이르지 못했거나 그런 기능을 상실했다면, 즉 조정에 실패한다면 어떻게 되는가? 조정 문제 해결의 완수만을 조건부로 하는 논변을 채택한다면 이 경우 책무성의 근거는 상실될 수밖에 없다(‘조정 실패’). 셋째, 조정 문제 해결을 위해 성립된 관행이 아닌 경우에는 기능주의 논변의 설득력은 약화될 수밖에 없다(‘비조정관행’). 넷째, 이 논변은 ‘역기능’의 문제는 고려하지 않는다. 소극적 의미에서 기능의 쇠퇴나 상실뿐만 아니라 본래 의도한 것과는 반대로 작용하는 역기능의 상황은 관행의 규범성을 근거 지우는데 있어서 중요한 변수가 될 수 있다(‘역기능’). 다섯째, 물가치적 기능주의는 목적-수단 공식에 의한 문제 해결의 측면에만 집중함으로써 관행이 성립·작용하는 일련의 과정 속에서 형성·공유되는 다양한 가치들을 포착하지 못할 수 있다(‘물가치적 기능주의’). 이러한 문제점과 한계들로 인해 기능주의 논변은 비완결성을 갖는다. 요컨대 기능주의 논변은 필요적 논변이긴 하지만 그 자체의 결함을 보완할 다른 논변에 의한 보충이 필요하다.

(1) 존중의 주체 및 대상

관행 존중의 주체 범위와 대상은 다층적이다. 절대적인 관행 준수 의무를 주장하는 길버트는 그 책무의 부담 주체나 방향을 철저히 ‘공동 창안자(co-creator)’로서 ‘합동 결의’의 상대방에 한정한다. 특히나 관행의 본질을 계약과 동일하게 취급하는 길버트에 따르면⁹⁴⁾ 책무 부담은 (명시적이건 묵시적이건) 계약의 직접 당사자만 부담하게 된다. 하지만 법적 관행의 복합적이고 다층적인 내적 구조를 고려한다면 이런 설명은 부적절하다. 마머도 지적하듯이,⁹⁵⁾ 관행을 이루는 참여자들⁹⁶⁾은 다양한 층위에서 존재한다. 관행에의 참여자는 구체적으로 ‘일선 참여자’와 ‘이선 참여자’로 구분할 수 있는데, 모두가 관행 존중의 주체가 된다.⁹⁷⁾ 다만 참여자의 유형에 따라 존중의 방식과 부담

94) 길버트의 관행 이론을 ‘계약 이론’으로 분류하고 특정화하는 견해도 있다. J. S. Latsis, “Is there redemption for conventions?,” *Cambridge Journal of Economics*, 2005, pp.715-718.

95) 마머는 법체계를 관행의 예로 들면서 “Divisions of Labor”라는 표제 하에 법체계를 이루는 구성원들 사이의 계층적 차이에 대해 설명한다. Marmor, *Social Conventions*, pp.46-49.

96) 관행 관련 주체들을 나타내는 표현은 다양하다. ‘일정한 인구집단 P의 구성원들(members of population P)’(루이스), ‘당사자들(parties)’(길버트), ‘구성원들’(마머) 등. 필자는 기본적으로 루이스나 마머의 정식을 대안 이론의 기초로 삼았다. 그리고 관행의 본질을 ‘계약’으로 규정하지 않는 이상, 관행에의 관련 주체는 직접적 이해 당사자에 한정되지 않는다. 결론적으로 필자는 ‘구성원’이라는 표현보다는 ‘일정 규모의 집단 P의 구성원들’이라는 표현이 적합하다고 생각하며, 이를 ‘관행에의 관련 행위자’의 면에서 보면 ‘참여자’라는 용어를 더 선호한다. (필자가 제안한 ‘법적 관행 정식’에도 두 가지 표현이 함께 사용되고 있음을 확인할 수 있다.) 왜냐하면 이러한 용어 선택은 ① 본고 I-3.에서 규범성 해명을 위한 방법론적 전제로 채택한 ‘1인칭 참여자 관점’과도 상응하며, ② ‘참여자’의 다양한 유형과 층위를 논함으로써 관행의 복잡성의 일면도 더 적절히 설명할 수 있으며, ③ III-2.에서 주장하는 ‘다층적 책무성’에 관한 설명 역시 일관된 방식으로 전개할 수 있기 때문이다. 또한 필자는 ‘일선 참여자’와 ‘이선 참여자’를 구분한다.

97) 이 설명을 적용할 수 있는 한 예로 2015년 5월 개정된 ‘상가건물 임대차보호법’ 제10조의4(권리금 회수기회 보호 등)를 들 수 있다. 이 법은 임대인이 권리금 계약의 직접 당사자가 아님에도 불구하고 ‘방해 금지 의무’를 부과하고, 이를 불이행시 손해배상책임을 지운다. 그런데 본고의 법학적 관행 이론에 따르면 임대인 역시 ‘이선 참여자’로서 관행 존중의 주체 범위 안에 포함되기에, 이 규정에 대한 이론적 분석과 정당화가 가능해진다.

정도는 다를 수 있다. 그리고 존중의 대상은 ‘관행 그 자체’가 된다. 만약 특정 관행의 내용 안에 그것을 준수할 책무까지를 포함하고 있다면, ‘그 관행에의 준수’가 존중의 대상이 될 수 있다.

(2) 존중의 내용 및 방식

‘관행 존중’의 법적 의미는 일차적으로 관행의 존재에 대한 인정과 수용을, 나아가 그 관행에 대한 준수를 요한다. 관행에 대한 존중이나 복종은 두 가지 방식으로 구체화될 수 있다. 통상적인 ‘적극적 방식(positive way)’으로는 해당 관행이 지시하는 바에 그대로 따름으로써 그 실현을 이행하는 복종이 있다. ‘소극적 방식(negative way)’으로는 관행의 실현을 방해하지 않을 책무를 들 수 있는데, 이 역시 관행 존중 혹은 준수가 구현되는 한 경로가 될 수 있다.⁹⁸⁾

(3) 존중의 정도

관행에의 존중은 관행의 실현을 보장하고 준수하는 것을 의미한다. 그렇다면 “이에 대한 존중은 어느 정도로 해야 하는가? 그 정도는 절대적이고 확정적인 것일까?” “관행 존중 원칙의 효력은 어디까지인가?” ‘보장해야 한다’는 명제도 맥락에 따라서는 그 외연을 어디까지로 보느냐에 따라 부당함이 발생할 수 있다. ‘관행 존중의 원칙’의 법적 위상은 일종의 법원칙으로 볼 수 있다. 그러므로 특히나 법체계 안에서 일정한 위상을 점하는 법적 관행의 경우에는 구체적인 사안에서 경쟁하는 법원칙들 간의 비교형량에 따라서 ‘관행 존중의 원칙’이 실현되는 비중과 효과가 정해질 것이다.⁹⁹⁾

규범으로서 관행은 추상적인 이상적 질서가 아니며, 사람들의 ‘실천됨’에 의해 그 존재론적 효력을 부여받는 실효적인 사실상의 질서다. 관행은 선행

98) 법복종의무와 관련한 중요한 문헌으로 William A. Edmundson (Ed.), *The Duty to Obey the Law*, Rowman & Littlefield Publishers, 1999.

99) 예컨대 “비과세 **관행 존중의 원칙**은 합법성의 원칙을 희생하여서라도 납세자의 신뢰를 보호함이 정의에 부합하는 것으로 인정되는 특별한 사정이 있을 경우에 한하여 적용되는 **예외적인 법 원칙**이다.”(대법원 2013.12.26. 선고 2011두5940) (밑줄 및 강조는 필자.) 예컨대 권리금 수수 관행을 둘러싼 법적 분쟁과 법제화 사례에서는 기본적으로 ‘사적 자치의 원칙’과 ‘관행 존중의 원칙’ 간의 긴장 관계를 내포한다고 볼 수 있다.

적 원리나 초월적 이념에 호소하는 것이 아니라, 구성원들의 끊임없는 상호 작용을 통한 참여와 헌신을 통해 형성·유지됨으로써 정당성을 획득한다. ‘관행 존중의 원칙’의 기저에는 그 공동체 구성원으로서 평온한 공존과 협력을 추구하는 이상이 자리한다. 그러나 때로는 그러한 근본적 가치나 이상을 현저히 위협하는 방향으로 관행 질서가 변모되고 부정적으로 변질될 수 있다. 그러한 경우 ‘관행 존중의 원칙’은 온전히 보장되기 어려울 뿐 아니라 바람직하지도 않을 것이다. 이것이 바로 다음 장에서 다룰 소위 ‘나쁜 관행’의 문제와 연결된다.

IV. 〈3단계〉: 관행 평가—‘나쁜 관행’의 문제

법이론으로서 관행 이론을 구상한다면, 관행의 규범성을 해명하고 분석하는 분류적 차원에서의 ‘존재론적 규범성론’ 뿐만 아니라 그것의 품질을 평가하고 효력을 재고할 수 있는 이론적 토대로서 ‘가치론적 규범성론’도 중요하다. 즉 우리는 규범으로서 관행에 대해 ‘분류’의 문제와 별개로 ‘평가’의 단계로 나아갈 수 있다. 관행으로서 자격을 인정받은 ‘진성 관행’ 중에도 어떤 의미에서 ‘나쁜 관행’으로 평가될 수 있는 관행이 있을 수 있다. 그렇다면 소위 ‘나쁜 관행’의 의미와 기준은 무엇이며, 그것의 효력은 어떻게 되는가? 합당하고 실용적인 법학적 관행 이론이라면 이러한 물음에도 답할 수 있어야 할 것이다.¹⁰⁰⁾ 이런 문제의식을 기초로, 이 장에서는 일종의 병리 현상인 ‘나쁜 관행’ 문제를 소재로 삼아 관행의 효력과 평가 문제를 다룬다. ① ‘나쁜 관행’은 관행인가? ② ‘나쁜 관행’의 의미와 판정 기준은 무엇인가? ③ ‘나쁜 관행’의 효력은 어떠하며 그것에 따를 의무가 있는가? 이것이 바로 필자가 IV장에서

100) 양선숙 교수도 지적하기를, “통상적 관행론은 나쁜 관행과 좋은 관행을 구분할 수 없다. CR을 만족하여 ‘관행’으로는 분류되지만 규범성을 갖는다고는 할 수 없는 행동규칙이 가능하다. 만약 우리에게 법 이론으로서의 관행론이 있어야 한다면, 그것은 관행 일반에 대한 이론에서 그치는 것이 아니라 ‘좋은 관행’을 적절하게 설명하는 것이어야 할 것이다.” 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해,” 『법철학연구』 제15권 제3권, 2012, 48면.

답하고자 하는 질문들이다.

1. ‘추정적 효력 테제’

관행 정식을 충족한 진성의 법적 관행은 우선 그 자체로 효력이 인정된다. 이를 ‘추정적 효력 테제(presumptive validity thesis)’라고 불러보자. ‘추정적 효력 테제’는 ‘관행 존중의 원칙’을 법적 명제로 변환한 것이다.¹⁰¹⁾ 효력 이론은 ‘요건’과 ‘효과’의 두 부분으로 구성된다.¹⁰²⁾ 법적 관행 정식을 충족한 법적 관행은 효력이 추정되며, 따라서 준수 의무가 수반된다. 다시 말해 ‘추정적 효력 테제’를 통해 존재하는 관행은 일차적으로 정당성을 갖는다. 그 논거로서 ① 발생적 차원에서 획득된 민주적 권위에 기한 자기 정당성 획득(‘발생적 정당성 논변’), ② 조정 문제에 대한 해법으로서 조정력과 조정적 권위(‘기능주의 논변’), ③ 심리학적 논거(‘심리학적 논변’)와 ④ 계약주의 논거(‘계약주의 논변’) 등이 가능하다. 관행 규범성의 원천을 해명하기 위해 동원된 논변들(Ⅲ장)이 관행의 ‘추정적 효력 테제’의 정당화 근거와도 중첩된다. 다만, 진성 관행에 부여된 효력은 확정적이거나 종국적이지 않다는 점에서 ‘추정적’이며, 따라서 임계점을 넘은 ‘나쁜 관행’은 무효화될 수 있다.

‘추정적 효력 테제’는 문턱점과 임계점을 갖는다. 예컨대 조정 관행의 경우에는 합리적인 조정력에 기한 기능주의 논변이 ‘추정적 효력 테제의 문턱점’ 역할을 한다. 그런데 법적 영역에서는 임계점에 대한 인식과 규범적 판단이 특히 중요하다. 법적 영역에서라면 관행의 추정적 효력은 재고되고 재평가 받는 과정이 요구될 수 있다는 것이 필자의 입장이다. 채무 산출적 규범성이 수반된 강력한 규범적 관행의 경우에도 만약 일정한 심사기준에 따라 ‘나쁜 관행’으로 평가받게 되면 ‘추정적 효력의 임계점’을 넘은 것으로 볼 수 있다. 즉 ‘나쁜 관행’의 경우에는 ‘추정적 효력 테제’가 부인되어 무효화되고, 그 결

101) 일부 실정법학에서는 ‘관행 존중의 원칙’이 법원칙의 위상을 갖기도 한다. 대표적으로 행정법학에서는 특히 “(비과세) 관행 존중의 원칙”을 신뢰보호원칙의 파생 원칙으로 설명한다.

102) 최봉철, “법의 효력: 요건과 효과를 중심으로,” 『법철학연구』 제17권 제3호, 한국법철학회, 2014.

과 그것에 따를 일반적 준수 의무는 부인될 수 있다. 이것이 바로 ‘추정적 효력 테제’가 만들어내는 실천적 효과다.

2. ‘나쁜 관행’의 의미와 기준

필자는 기본적으로 실증주의적 규범관¹⁰³⁾에 입각하여, ‘나쁜 관행’의 개념적 가능성을 인정한다.¹⁰⁴⁾ 이런 관점을 전제할 때 규범은 규범이되 ‘나쁜 규범’, 즉 ‘나쁜 관행’을 판별하고 그 효력과 정당성을 논할 수 있게 된다. 이는 특히 ‘법적 관행’에 있어 중요한 의미를 갖는다.

(1) ‘무의미한 관행’ vs. ‘나쁜 관행’

우선 ‘나쁜 관행(bad convention)’과 ‘무의미한 관행(pointless convention: 아래 표에서 ‘PC’로 약칭함)’¹⁰⁵⁾을 구별할 필요가 있다. ‘무의미한 관행’은 약한 의미와 강한 의미로 구분할 수 있다. ‘약한 의미에서의 무의미한 관행’은 사람들이 그 관행을 거의 준수하지 않음으로써 준수 의존적 이유가 제거되는 상황을 뜻한다. 관행 성립의 필수요건 중 하나는 일반적 준수 의존성인데, 실효적 준수가 없다면 그 관행은 ‘무의미’할 수 있다. 반면에 ‘강한 의미’도 가능하다. ‘관행 정식’(II-2.)의 조건 (1)에 따르면 관행은 어떤 가치나 목적, 필요에 대한 규범적 응답으로서 특정한 목표나 가치를 전제한다. (예컨대, 선착순이나 한줄

103) 여기서 ‘실증주의적’이라는 표현은 고전적 법실증주의자 오스틴(John Austin) 구분을 따른 것이다. 즉 무엇이 법인지의 문제(분류의 문제)와 그것의 장단의 문제(평가의 문제)는 다르다는 입장을 말한다. 또한 필자는 샤피로의 다음과 같은 설명에 동의한다. “당신이 하면 안되는 것을 하라고 말하는 규범은 유효하지 않은 규범(invalid norm)이다. 이것은 나쁜 규범이지 규범이 아닌 것(nonnorm)은 아니다.” Shapiro, *Legality*, pp.40-42.

104) 이런 인식의 루이스의 글에서도 발견된다. “조정균형은 현저하다(salient): 어떤 특징적 의미에서 그것의 독특함에 의해 나머지로부터 두드러지는 것. 그것은 특별히 좋을 필요는 없다; 특별히 나쁠 수도 있다. 단지 수범자가 알아차릴 식으로 독특해야 한다.” Lewis, *Convention*, p.35.

105) 그런데도 ‘무의미한 관행’을 언급하면서 유행에 뒤떨어진 에티켓 규칙을 예로 든다. 또한 그는 “가치있는 관행(valuable convention)”이란 표현도 사용한다. Leslie Green, *The Authority of the State*, Oxford University Press, 1999, p.90.

서기 관행은 ‘평등주의’ 가치를, 우측 주행은 ‘안전보장’과 ‘목적지에 정시 도착’이라는 목적에 봉사한다.) 관행의 내용이나 작동은 애초에 그것이 추구했던 목적이나 가치를 훼손하지 않아야 한다. 그런데 만약 어떤 관행이 그것의 존재 조건을 이루는 가치나 목적에 명백히 반하여 형성되거나 그런 방향으로 변질되어 작동된다면 그 관행은 합목적적이지 못하며, 따라서 ‘강한 의미에서 무의미한 관행’으로 볼 수 있다.

그렇다면 ‘무의미한 관행’과 ‘나쁜 관행’은 어떤 관계가 있을까? 우선 모든 단계의 ‘무의미한 관행’이 곧바로 ‘나쁜 관행’임을 함축하는 것은 아니다. ‘무의미한 관행’은 ‘나쁜 관행’으로 심화되는 계기가 될 수는 있지만, 나쁜 관행은 더 강력한 외적 기준에 의해 판정되기도 한다. 요약하자면, ‘무의미한 관행’은 대부분 ‘나쁜 관행’에는 이르지 못한 것으로서 ① (어떤 이유에서건) 사람들이 점차로 준수하지 않아 실효성이 현저히 약화된 관행(‘실효성 심사’), ② 애초에 그 관행이 전제한 목표나 취지에 반하거나 그렇게 변질된 관행(관행 정식의 조건 (1) 위배; ‘합목적성 심사’) ③ (가장 약한 의미에서) ‘나쁜 관행’이 있다. 이를 간단히 표로 정리하면 다음과 같다.

[표 5] ‘무의미한 관행(PC)’과 ‘나쁜 관행(BC)’

	‘약한 의미’에서의 PC	‘강한 의미’에서의 PC
내용	사람들이 점차로 준수하지 않아 실효성이 현저히 약화	애초에 그 관행이 전제한 목적·취지에 위배
관행 정식	관행 정식의 조건 (3) : ‘일반적 준수 의존성’	관행 정식의 조건 (1) : ‘목표·가치의 전제’
판단 기준	실효성 심사	합목적성 심사
위상	고유한 의미에서의 ‘무의미한 관행’	‘무의미한 관행’ & 가장 약한 의미의 ‘나쁜 관행’

(2) ‘나쁜 관행’의 의미: 도덕적 차원과 비도덕적 차원

그렇다면 보다 적극적인 차원에서 논할 수 있는 ‘나쁜 관행’의 의미와 기준은 무엇일까? ‘나쁜’이라는 평가적 속성은 불확정적이다. 특히 관행의 맥락에서 ‘나쁜’의 의미는 다원적으로 이해될 필요가 있다. 그 의미와 판정 기준을

도덕적 차원과 비도덕적 차원으로 구분해보자.

‘도덕적 차원’에서 나쁜 관행은 명백히 반도덕적 내용을 담고 있는 것을 말한다. 가령 가상 공동체 C에서는 어떤 승부게임에서 패하면 승자가 패자를 살해하는 것이 관행적으로 행해져왔다고 해보자. 이것은 관행인가?¹⁰⁶⁾ 경우에 따라서는 그런 규칙이 관행 정식을 충족한다고 해석될 수도 있다.¹⁰⁷⁾ 필자의 설명에 따르면 이는 진성 관행이긴 하지만 ‘도덕적으로 나쁜’ 관행인 것이다.

‘비(非)도덕적 차원(non-moral dimension)’에서 나쁜 관행이 가능한 예로는 ‘과학적 차원’과 ‘체계 정합성 차원’을 들 수 있다. 과학적 차원의 예를 살펴보자. A 사회에는 오랜 기간 에스컬레이터에서 한줄서기가 시행되어왔다. 이는 급하게 가야하는 사람을 위해 한 줄을 비워둠으로써 통행자를 배려하고 질서를 유지하는 관행이다. 그런데 문제는 한줄서기로 인해 하중이 한쪽에 쏠리면서 안전사고가 많이 발생한다는 점이다. 이런 이유로, 에스컬레이터 한줄서기 관행은 ‘안전’이라는 과학적 차원에서의 객관적 기준에 따라 심사한 결과 나쁜 것으로 판정될 수 있다. 즉 에스컬레이터 한줄서기는 관행 정식을 충족한 진성 관행이긴 하지만 과학적 차원에서 ‘나쁜 관행’이다. 비도덕적 차원에서 나쁜 관행이 가능한 또 다른 경우로 ‘체계 정합성 위반’이 있다. 다양한 규범 질서들 중에서 법질서가 갖는 특징 중 하나는 ‘체계성’과 ‘정합성’이다. 법에서 체계 정합성 유지는 중·횡의 모든 방향에서 중요하다. 그런데 만약 어떤 관행이 형식적이나 실질적으로 그것이 속한 상위 체계와의 정합성을 현저히 해친다면, 이는 ‘나쁜 관행’으로 평가될 수 있다. 예컨대 어떤 관행이 동일 사안을 규율하고 있는 법규칙에 반하는 내용을 담고 있다면 체계적 정당성을 상실한 것이며,¹⁰⁸⁾ 따라서 ‘위법한 관행’으로서 ‘나쁜 관행’이 된다. 또한

106) 극단적 상대주의자이자 도덕 관행주의자인 하만은 살인행위까지도 관행으로 설명한다. 길버트 하만(김성환 옮김), 『도덕의 본성』, 철학과 현실사, 2005.

107) 반대로 이러한 반도덕적인 규칙에 대해 관행의 지위를 부정하는 논증도 가능하다. ‘대안 정식’의 첫째 조건인 “R은 특정한 목표나 가치를 전제로 하는 협력적 실천”에 비추어 보면 위 관행은 그것이 구현하고자 하는 가치나 목표가 합리적 주체로서 합당하게 수용할 만한 것이라고 보기 어렵다. 또한 ‘임의성’ 조건과 관련해서도, 적절한 대안관행을 가지고 있지 않다. 따라서 이는 ‘나쁜 관행’이 아니라 애초에 ‘관행 아닌 것’으로 판정될 수도 있다.

헌법조항이나 헌법적 가치에 명백히 반하는 관행 역시 소위 ‘위헌적 관행’¹⁰⁹⁾으로서 ‘나쁜 관행’으로 평가될 수 있다.

(3) 독자적인 외적 심사 기준의 가능성

결론적으로 관행을 비판적으로 성찰하고 평가할 객관적 기준이 요청된다. 그렇다면 ‘나쁜 관행’을 규율할 이론적 자원은 어디서 구할 수 있을까? 이는 관행의 개념이나 본성에 대한 성찰로부터 온전히 확보 가능한가? 평가적 차원에서 필자가 궁구하는 관행 규범성의 물음은 다음과 같다.

① 관행성의 타락이나 극단화를 규율하는 원리를 관행의 개념론 안에서 구할 수 있을까? ‘관행 정식’은 최소한의 심사기준 역할을 하는 내재적 개념 장치를 포함하고 있는가?

: <내적 제약 원리의 가능성 문제>

② 관행에만 특화된 비판적 평가 기준을 제시하는 것이 가능할까?

: <외적 제약 원리의 독자성 문제>

첫 번째 물음과 관련하여, 필자는 본고 II장의 ‘법적 관행 정식’(이하 ‘대안 정식’)의 조건 (1): “규칙 R은 특정한 목표나 가치를 전제로 하는 협력적 실천”을 통해 일응의 답을 제시했다. 즉 조건 (1)에 따르면, 관행은 반드시 어떤 목적이나 가치를 전제로 하며, 그 질서는 협력적 속성을 갖는다. 그런데 만약 어떤 관행이 애초에 그것이 전제하는 가치나 목표에 현저히 반하게 된다면

108) 이런 주장이 ‘관행과 법규칙은 일률적인 위계적 서열관계 속에 있으며, 관행은 법규칙에 비해 열위에 있다’는 주장을 포함하는 것은 아니다. 관행과 실정법규칙은 다양한 차원에서 상호 견련되어 있다. 예컨대 일부 법관행주의는 법의 본질을 관행으로 파악하기도 한다. 다만 여기서는, 국내법체계 안에서 규범의 공식화 및 실정화 정도를 기준으로 한 체계적 효력, 체계적 정합성에 초점을 맞춘 것이다. 조정적 법관념을 지지하는 대표적인 국내 학자로는 조홍식, 『사법통치의 정당성과 한계』, 제2판, 박영사, 2009 참고.

109) 실제 한국 정치사에서도 ‘위헌적 관행’ 여부가 논란이 된 사건이 있다. 정종섭, “대통령의 국무총리 임명에 대한 국회의 동의,” 『헌법학연구』 제4권 제2호. 이 글에서는 “국무총리서리” 제도에 대한 논쟁을 다룬다. “국무총리서리” 제도에 대해 박형오 의원은 “헌법의 규정을 무시한 관행 아닌 관행”으로, 권영성 교수는 “위헌적 관행”으로, 그리고 그 글의 필자인 정종섭 교수는 “폐습”으로 표현한다.

이는 조건 (1)을 위반한 것으로 볼 수 있다. 그 경우 관행 자격성은 부인되며, 따라서 추정적 효력도 박탈된다. 필자는 이를 ‘합목적성 심사’ 기준으로 논하였다. 하지만 이런 설명은 제한적일 수밖에 없다. 왜냐하면 특정 관행이 전제하는 가치나 목표는 꼭 도덕적인 것일 필요는 없으며, ‘협력적 실천’이라는 요건 역시 소극적으로만 기능하기 때문이다. 그 결과 대안 정식의 첫 번째 조건(‘합목적성 심사’)은 ‘나쁜 관행’을 판정할 최소한의 문턱 기준은 되지만 적극적인 통제 원리가 되긴 어렵다. 결국 관행 외부의 기준에 호소하게 된다는 결론에 이르게 된다. 즉 관행 외부에 존재하는 가치 원리나 기제에 의한 심사와 평가에 의존할 수밖에 없다.

두 번째 물음, 즉 관행에만 특화된 평가 기준을 제시하는 것은 가능할까? 다시 말해 ‘나쁜 관행’을 판정할 독자적인 외적 제약 원리나 기준을 마련할 수 있을까? 결론부터 말하면, 관행에만 특화된 독자적인 심사 기준을 제시하는 것은 사실상 어려우며 합당하지도 않을 수 있다.¹¹⁰⁾ 그럼에도 불구하고 관행에 대해서도 가치판단과 ‘평가’가 가능하고 필요하다는 점을 인식하는 것은 이론적이나 실천적으로 중요한 의미를 갖는다. 이것이 바로 본고의 ‘법학적 관행 이론’이 지향하는 바이다. 하지만 궁극적으로는 관행의 특수성을 보존하면서도 보편적 원리와 조화 가능한 기준 마련이 요청된다.¹¹¹⁾

110) 관행을 이루는 기본 단위는 사회적 규칙이며 이는 구성원들에게 규범으로 기능한다. 그렇다면 우리는 규칙 이론이나 규범일반이론, 정의론 등에서 널리 수용되어온 여러 기준들을 참고할 수 있다. 예컨대 소극적 평가 기준으로 하트가 비판도덕을, 라트브르흐가 ‘참을 수 없을 정도의 부정의’라는 공식을 제시한 것과 유사한 차원의 논의를 크게 벗어날 수는 없을 것이다.

111) ‘나쁜 관행’을 판별하는 구체적 심사 기준은 필자의 후속 논문을 통해 구명할 것이다. 여기서는 잠정적으로 다음의 세 기준과 요지만 소개한다.

심사기준		‘나쁜 관행’의 핵심 내용	
①	합목적성 심사 (내적기준)	관행이 구현하고자 하는 목적·취지나 가치에 반하거나 이를 왜곡하지 않는다.	
②	정합성 심사 (외적기준)	공동체 P의 상위 규범질서 및 인접/연합질서와의 원리 및 체계 정합성을 현저히 해치지 않는다.	
③	공정성 심사 (외적기준)	형평과 공정성의 원리에 위배되지 않는다.	
		③-A	관행을 통한 공동이익(共益, common interest) 실현이 공적 이익(公益, public interest)을 현저히 위협하지 않는다.

3. ‘나쁜 관행’의 처우와 그 해결

‘나쁜 관행’에 대한 제도적 개선과 안정적이고 효율적인 처리를 위해서는 때로는 국가 주도적인 조치가 필요하고 유용하다.¹¹²⁾ 하지만 이런 접근이 문제 해결을 위한 유일하고 선도적인 방안이 될 수는 없다. 근본적이고 바람직한 해결책은 관행성의 소멸을 통한 점진적이고 자율적인 방식이다. 즉 ‘나쁜 관행’이 역으로 ‘무의미한 관행’이 되고, 최종적으로는 ‘관행 아닌 것’으로 변모되는 자율적 메커니즘 실현이 이상적이다. 이를 위해 국가의 개입과 지원은 보완책 역할을 한다. 결국 ‘나쁜 관행’에 대한 비판적 성찰을 통한 보편적 인식 확대와 공감대 형성, 그리고 공적 담론의 장을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다. 이런 과정에서 본고의 ‘법학적 관행 이론’이 이론적 자원을 제공하며, 실천적으로도 촉매 역할을 할 수 있으리라 기대한다.

V. 맺으며

관행이란 합리적 주체가 공동의 조정 혹은 협력 문제에 직면하여 실천적인 추론 과정을 통해 수립된 균형점으로서, 명시적인 합의나 약속이 없이도 행위자들 간의 사회적인 상호작용을 통해 형성되고 자율적으로 존속하는 묵시적인 규범적 질서이다. 관행은 실천됨을 존재론적 기반으로 삼는 특별한 사회적 규칙으로서, 그 자체의 메커니즘 상 참여자에게 행위 이유를 제공하고,

		③-B	민주적 공공성에 현저히 반하지 않는다.
--	--	-----	-----------------------

112) 예컨대, 박효종 교수는 ‘불의한 관행’이나 ‘비효율적인 관행’에 대한 교정자나 개혁자로서의 국가의 역할을 강조한다. “국가 권위의 기능이란 조정 문제에서 해법을 제시하는데 있는 것이 아니라, 조정 문제의 해결책이 경직된 형태로 공고화되지 못하도록 발휘하는 데 있으며, 혹은 비관행적인 해결책을 강행하는데 있다.” (밑줄은 필자.) 박효종, 『국가와 권위』, 박영사, 2001, 382면. 하지만 관행 규범의 개혁자로서 국가의 독립적인 역할과 능력에는 한계가 있다. 예컨대 가정의례준칙의 실패 사례, 미국 금주법의 실패 사례와 같은 여러 역사적인 실증 예들이 이 주장을 뒷받침한다.

행위를 향도하며, 준수 의무를 창출할 수 있는 규범이다.¹¹³⁾

본고에서 필자는 관행을 본격적인 법적 문제로 다루고, 이를 위한 분석틀을 제시하는 체계적인 ‘법학적 관행 이론’ 정립을 목표로 했다. 이를 위해 필자는 ① ‘일반적인 사회적 관행 이론’의 차원에서 기존 이론들의 한계를 보완하고, ② 법적 영역에서 유의미하게 고려되는 ‘법적 관행’ 개념을 제시하고 법적 영역의 특수성을 반영한 대안적 관행 이론을 마련하고자 하였다. 본고의 ‘법학적 관행 이론’은 세 단계로 구성되는데, 이는 규범성 담론의 세 차원—개념분석·정당화·평가—과 연계되어 있다. 규범성에 대한 탐구는 1인칭 참여자의 실천적 추론의 차원에서 ‘이유에 기반한 접근’을 통해 가장 잘 해명될 수 있다. 이런 방법론적 전제 하에, 위의 틀을 기초로 필자는 ‘법적 관행’의 개념과 요건을 제시하고(II), 규범으로서 관행의 특징을 해명한 후, 관행 규범성의 원천과 정당화 근거를 논하였다(III: ‘존재론적 규범성론’). 그리고 평가적 차원에서 ‘나쁜 관행’의 효력과 평가 문제(‘가치론적 규범성론’)를 규명하고자 했다. 이것이 ‘법학적 관행 이론’의 세 단계를 이룬다.

결론적으로 필자는 법학적 관행 이론의 각 단계별로 다음의 점들을 밝히고자 했다. 첫째, 관행 정식을 충족한 진성 관행은 특별한 종류의 규범이다(‘법적 관행 정식’)[1단계: 개념분석적 차원(II)]. 둘째, 관행은 여러 차원에서 규범적 위계를 가지며, 관행 규범성의 원천(源泉)은 다층적 논변으로 정당화될 수 있다(‘관행의 규범적 위계’ 및 ‘다층적 정당화 논변’)[2단계: 정당화 차원(III)]. 셋째, 진성 관행은 추정적 효력이 있지만, ‘나쁜 관행’의 경우에는 그 효력이 부인되며 준수 의무가 없다(‘관행존중의 원칙’ 및 ‘추정적 효력테제’)[3단계: 평가적 차원(IV)].

사회적 실재(social reality)로서 원형적 관행은 일종의 불문율이자 자율적인 연성규범이다. 그런데 영역에 따라서는 관행이 실정법 못지않은 규범력과 위상을 갖는다. 또한 입법이나 사법의 경로를 통해 법체계로 흡수되는 잠재적 법원(法源)으로서의 관행은 단지 공식적인 제도적 승인만 받지 않았을 뿐 실

113) 이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요소—관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초,” 168-169면.

질적인 규범력에 있어서는 법 못지않다. 따라서 법적 관행 개념, 그리고 그 효력 및 평가는 매우 중요하다. 경우에 따라서는 이런 문제가 법적 분쟁의 대상이 되고, 법체계나 법기관의 정당성에 대한 도전이 될 만큼 중요한 쟁점이 된다. 그리고 특히 ‘나쁜 관행’의 문제는 최근 사법이나 입법 과정을 통해 실제 양음(亮陰)의 실질적 법원(法源)으로 전환되고 법제화되어 해결된 경우들도 적잖이 볼 수 있다.

이러한 배경 하에, 본고는 ‘법적 관행 정식’을 제안하고, 체계적인 법학적 관행 이론을 정립하고자 하였다. 관행을 둘러싼 수많은 법적 분쟁의 상황들은 결국 기존 관행에 대한 존재나 효력을 인정받기를 주장하는 쪽과, 기존에 관행이라고 말해져온 어떤 질서가 부당함을 주장하면서 그것의 존재나 자격, 효력을 부정하려는 쪽 간의 공방이 기본 구도를 형성한다. 적절한 법학적 관행 이론이라면 이런 딜레마적 상황을 극복하기 위한 이론적 자원도 제공할 수 있어야 할 것이다. 만약 본고의 제2단계 연구 목표¹¹⁴⁾가 일부나마 달성될 수 있다면 한편으로 다음과 같은 실천적 기여를 할 수 있을 것이다. 우선 ‘회고적이고 반성적인 차원’에서 보면, 본 연구는 기존에 ‘관행’이란 이름 아래 유지되어 왔던 특정 질서에 대해 관행으로서의 존재나 효력을 적극적으로 주장하는 측과, 그것의 불합리나 부조리를 근거로 효력을 부인하는 측 양쪽 모두 균형 있게 참조 가능한 이론이 될 수 있다. 또한 이는 관행의 효력에 대한 재평가 작업을 수반한다. ‘미래지향적이고 전향적인 차원’에서 보면, 본 연구는 새로운 영역이나 문제 상황에서 실제로 관행이 합당한 규범으로 형성되고 인정받을 수 있는 이론적 토양을 제공할 수 있다. ‘법적 관행’이 입법·사법 경로를 통해 실질적인 규범력을 확인받고 법원(法源)으로 흡수되는 과정에서 그 건전성에 대한 이론적 탐구와 평가 기준 마련은 중요하다. 법이란 본디 진공 속에서 주어진 것이 아니라, 우리 공동의 삶 속에서 형성된

114) ① 관행의 개념과 존재 조건, 규범성의 원천 및 정당화 근거

②-A. 관행성을 보존하면서도, 변화와 혁신의 가능성을 허용하는 유연한 관행 개념과 동적 이론: 개념과 본성의 문제: 〈일반이론 차원〉

②-B. 관행성의 극단화를 제어하고, ‘나쁜 관행’을 평가할 수 있는 이론: 효력과 평가의 문제: 〈법이론 차원〉 (본고의 각주 12와 동일함.)

규범적 씨앗을 발굴해내고 제도적으로 승인·재평가해가는 과정의 산물이기 때문이다.

다만 본고에서는 사회적 현상으로서 실재하는 사회적 관행에 편향된 인식 관심을 기초로 이론을 구체화하였다. 하지만 전술한 바와 같이, 법에 있어서 관행의 문제는 또 한 차원에서 중요한 의미를 갖는다. 즉 법의 토대와 권위의 정당화 근거를 관행에 기해서 설명하는 ‘법관행주의(legal conventionalism)’가 그것이다. 그간 ‘사회적 관행 이론과’ ‘관행주의’는 분리되어 발전되어온 경향이 있고, 본고의 논의 역시 전자에 치중되어있다. 하지만 양자는 결코 분리될 수 없으며 상호 참조하고 소통할 때 완전해질 수 있을 것이다.¹¹⁵⁾ 물론 본고에서 제시한 ‘법학적 관행 이론’은 분명 두 노선 모두를 염두에 두고 통합 이론으로서 고안된 것이며, 각 영역에 일정한 시사점을 줄 수 있으리라 생각한다. 이러한 대안 이론을 기초로, 기존에 협소하게 이해되던 법관행주의 역시 재구성될 수 있으며 또 그러할 필요가 있다고 생각한다.¹¹⁶⁾¹¹⁷⁾ 본고의 ‘법학

115) 박준석 교수도 이와 같은 주장을 한다. “관행주의와 사회적 관행에 대한 복합적 이해는 특히 규범성의 문제를 대하는 우리의 시선을 밝히는 데 도움을 줄 수 있다. 박준석, “관행과 법의 지배,” 『법철학연구』 제16권 제3호, 한국법철학회, 2013, 114면.

116) 필자는 특히 법철학/법이론 영역에서 양자는 그 자체로 고유한 문제군을 형성하고 있으며, 각각이 충분히 심층적으로 고찰될 필요가 있다고 생각한다. 이는 순차적으로 연구 성과를 쌓아나갈 필요가 있는 거대 프로젝트라고 생각한다. 그런 연유로 본고에서는 우선 사회적 현상으로서 존재하는 사회적 관행 그 자체에 인식관심을 집중하여 문제를 풀어가고자 하였다. 따라서 ‘법관행주의’와 관련한 또 다른 한 축은 후속 논문으로 구명할 것을 약속드린다. 대안적인 ‘법철학적 관행주의(jurisprudential conventionalism)’ 구상에 관한 필자의 핵심 명제와 그에 대한 설명은 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 제5장 제3절 및 제6장 제3절 참고.

117) 본고의 ‘법학적 관행 이론’은 실정법학이나 법실무에서 적용 가능한 실천적 이론을 지향한다. 이를 위해서는 이론을 사례에 적용하여 적실성을 검증하는 것이 필요한데, 본고에서는 지면의 한계 상 담지를 못한 아쉬움이 남는다. 하지만 법적 관행 연구를 위한 최우선 과제는 충실한 이론 정립에 있음은 자명하다. 따라서 본고의 ‘법학적 관행 이론’의 틀을 기초로 구체적인 판례 및 실정법에 적용한 연구는 후속 논문으로 이어갈 것을 약속드린다.

적 관행 이론' 구상이 그 프로젝트를 실현하기 위한 출발점이자 주춧돌로서 그 길에 작으나마 보탬이 될 수 있기를 희망하며 글을 맺는다.

참고문헌

I. 국내문헌

- 김기창, “성문헌법과 ‘관습헌법,’” 『공법연구』 제33집 제3호, 2005.
- 김도균, “권리담론의 세 차원: 개념분석, 정당화, 제도화,” 『법철학연구』 제7권 제1호, 한국법철학회, 2004.
- 김도균, 『권리의 문법—도덕적 권리·인권·법적 권리』, 박영사, 2008.
- 김도현, 『법이란 무엇인가』, 동국대학교출판부, 2007.
- 김정욱, “권리금에 대한 법경제학적 접근,” 한국개발연구원, 2010.
- 김현철, “형식적 권리론—권리의 개념구조에 대하여,” 『법철학연구』 제5권 제1호, 한국법철학회, 2002.
- 김형배, 『노동법』, 박영사, 2014.
- McCain, Roger A.(이규억 옮김), 『게임이론』, 시그마프레스, 2013.
- 박준석, “관행과 법의 지배,” 『법철학연구』 제16권 제3호, 한국법철학회, 2013.
- 설, 존(심철호 옮김), 『정신·언어·사회』, 해냄, 2000.
- 박효중, 『국가와 권위』, 박영사, 2001.
- 신옥영, “상가건물임대차보호법의 권리금 회수기회 보호에 관한 연구,” 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2017.
- 심헌섭, “규범의 일반이론에 관한 연구,” 『분석과 비판의 법철학』, 법문사, 2001.
- 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해,” 『법철학연구』 제15권 제3권, 한국법철학회, 2012.
- 이현경, “관행에 관한 연구: 사회적 관행에서 법적 관행으로,” 서울대학교 대학원 법학박사학위논문, 2016.
- 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰,” 『법학논총』 제34집 제3호, 한양대학교 법학연구소, 2017.
- 이현경, “동적 관행 이론,” 『강원법학』 제51권, 강원대학교 비교법학연구소, 2017.
- 이현경, “법적 관행의 개념과 그 요건,” 『법학논총』 제37권 제2호, 전남대학교 법학연구소, 2017.
- 이현경, “사회적 관행 이론의 세 모델: 비판적 검토,” 『법학논집』 제21권 제3호, 이

화여자대학교 법학연구소, 2017.

이현경, “제도적 사실로부터 제도적 규범질서로: 맥코믹의 제도적 법개념 발전과정과 변천에 관한 고찰,” 『법학논총』 제30권 제2호, 국민대학교 법학연구소, 2017.

이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요소: 관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초,” 『법철학연구』 제20권 제1호, 한국법철학회, 2017.

정종섭, “대통령의 국무총리 임명에 대한 국회의 동의,” 『헌법학연구』 제4권 제2호.

조홍식, 『사법통치의 정당성과 한계』, 제2판, 박영사, 2009.

최봉철, “법의 효력: 요건과 효과를 중심으로,” 『법철학연구』 제17권 제3호, 한국법철학회, 2014.

최송화, “공익의 법문제화,” 『서울대학교 법학』 제47권 제3호, 서울대학교 법학연구소, 2006.

최송화, 『공익론』, 서울대학교 출판문화원, 2013.

코스가드, 크리스틴 M.(강현정 · 김양현 옮김), 『규범성의 원천』, 철학과 현실사, 2008.

하딘, 러셀(황수익 옮김), 『집합행동』, 나남출판, 1995.

하만, 길버트(김성한 옮김), 『도덕의 본성』, 철학과 현실사, 2005.

II. 외국 문헌

Araszkiewicz, Muchal · Banas, Pawel · Gizbert-Studnicki, Tomasz · Pleszka Krzysztof (Eds.), Problems of Normativity, Rules, and Rule-Following, Springer, 2015.

Besson, Samantha, The Morality of Conflict: Reasonable Disagreement and the Law, Hart Publishing, 2005.

Binmore, Ken, “Do Conventions Need to Be Common Knowledge?,” Topoi, Vol. 27, 2008.

Coleman, Jules L., “Authority and Reasons,” The Autonomy of Law, Oxford, 1996.

Coleman, Jules L., The Practice of Principle, Oxford University Press, 2001.

Edmundson, William A.(Ed.), The Duty to Obey the Law, Rowman & Littlefield

- Publishers, 1999.
- Finnis, John, Natural Law & Natural Rights, Second Edition, Oxford University Press, 2011.
- Gilbert, Margaret, "Social Convention Revisited," Topoi, Vol. 27.
- Gilbert, Margaret, Joint Commitment: How We Make the Social World, Oxford University Press, 2014.
- Gilbert, Margaret, On Social Facts, Routledge, 1989.
- Goldoni, Marco, "Multilayered Legal Conventionalism and the Normativity of Law," in New Essays on the Normativity of Law, Hart Publishing, 2011.
- Green, Leslie, The Authority of the State, Oxford University Press, 1999.
- Hume, David, A Treatise of Human Nature: A Critical Edition, Vol 1: Texts, Norton, David Fate and Norton, Mary J.(Eds.), Oxford University Press, 2007.
- John R. Searle, The Construction of Social Reality, New York, 1995.
- Latsis, J. S., "Is there redemption for conventions?," Cambridge Journal of Economics, 2005.
- Lewis, David, Convention, Blackwell Publishing, 1969.
- MacCormick, Neil and Weinberger, Ota, An Institutional Theory of Law: New Approach to Legal Positivism, D. Reidel Publishing Company, 1986.
- Marmor, Andrei and Sarch, Alexander, "The Nature of Law," in Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2001.
- Marmor, Andrei, "On Convention," Synthese, Vol. 107, No. 3, 1996.
- Marmor, Andrei, Interpretation and Legal Theory, Oxford University Press, 1992.
- Marmor, Andrei, Social Conventions: From Language to Law, Princeton University Press, 2009.
- Murphy, James Bernard, "Habit and Convention at the foundation of custom," Perreau-Saussine, Amanda, · Murphy, James Bernard (Ed.), in The Nature of Customary Law, Cambridge University Press, 2007.
- Oxford English Dictionary Online, Oxford University Press, 2010.
- Postema, Gerald J., "Conventions at the Foundation of Law," in The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Peter Newman (Ed.), 1998.

- Postema, Gerald J., *Legal Philosophy in the Twentieth Century: The common law world*, Springer, 2011.
- Raz, Joseph, "Explaining Normativity: On Rationality and the Justification of Reason," in *Normativity*, Blackwell, 2000.
- Rescorla, Michael, "Convention," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2011.
- Shapiro, Scott J., *Legality*, Harvard University Press, 2011.
- Sillarii, Giacomo, "Common Knowledge and Convention," *Topoi*, Vol. 27, 2008.
- Siltala, Raimo, "Legal Conventionalism: Law as an Expression of Collective Intentionality," in *Law, Truth, and Reason*, Springer, 2011.
- Sugden, Robert, "Conventions," in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Peter Newman (Ed.), 1998.
- Vanderschraaf, Peter and Sillari, Giacomo, "Common Knowledge," *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. 2013.
- Weinberger, Ota, "The Role of Rules," *Ratio Juris*, Vol. 1, No. 3, 1988.

Abstract

Legal Convention Theory

—Focusing on Three Dimensions of Discourse on Normativity of
Convention: conceptual analysis, justification, and evaluation—

Lee, Hyun-Kyung*

Convention is the equilibrium agreed upon by reasonable subjects facing common problems that need coordination or cooperation through practical reasoning process, an implicit normative order which is formed through the social interaction among the actors without explicit consent or agreement and is persistent autonomously. Previous theories on social conventions can be categorized into three approaches, namely: (i) the ‘coordination solution model’ of Hume and Lewis, (ii) the ‘alternative model’ which has emerged based on a rejection of Lewis’ fundamental premises, (iii) and the ‘multi-layered alternative model’ of Marmor. The author indicates that previously existing main theories on convention have, in spite of various merits, certain problems and limits on two dimensions: namely, the dimension of a ‘general theory’ on social conventions, and the dimension of a ‘legal theory’ thereon. In the former sense they cannot appropriately grasp the ‘dynamic and complex’ nature of conventions, whereas they fail to elucidate the ‘normativity’ of convention in the latter sense. In order to overcome these defects of the existing theories, the author claims for the eventual necessity to formulate an ‘alternative legal convention theory’. The alternative theory includes a reconstruction of the

* Senior Researcher, Center for Legal Theory, Seoul National University./
Collegiate Professor, School of Undergraduate Studies, DGIST.

concept of 'legal convention', and has as its constructive elements the elucidation of the dynamics and complexity of convention, and normativity of convention. In this article, the author focus on elucidating the normativity of convention in multiple perspective, based on three different dimensions of discourse on normativity; ① 'conceptual analysis', ② 'justification', ③ 'evaluation'. As an conceptual analysis, the author reconstruct the concept of 'legal convention', which contain the dynamic and intrinsic normative nature of convention on the premise of 'convention as norm'.('legal convention formula') In the latter part of the paper, the author investigates the normativity of conventions, arguing against two kinds of skeptics and its evaluational function which tries to solve the problem of 'bad convention'. The author insist following three main thesis, distinguishing between 'ontological normativity' and 'evaluative normativity', (1) 'normative hierarchy of convention', (2) 'presumptive validity thesis', (3) 'multiple justification argument'. The author claim that genuine conventions which satisfy the alternative convention formula should be respected. Since the convention has a presumptive validity, we have prima facie obligation to conform to it.('presumptive validity thesis') However, so called 'bad conventions', different from pointless conventions, loosen their presumptive legitimacy, and then, we don't have any general obligation to obey it. The author explains the meaning of 'bad convention' and gives several criterion to judge it, in a evaluative normativity dimension.

색인어

관행(convention), 법적 관행(legal convention), 법학적 관행 이론(legal convention theory), 규범성(normativity), 나쁜 관행(bad convention)